

詐欺罪的財產損害與被害人之錯誤^{*} —— 法益關係錯誤說的應用嘗試

黃士軒^{**}

摘要

本文主要目的是對詐欺罪可能存在的過度擴張處罰之危險，在解釋上尋求限定的可能性。本文首先以我國詐欺罪實務為對象，詳細考察詐欺罪被害人所生錯誤之內容及財產損害概念，掌握我國實務在此二問題上存在的不同立場，並指出這些不同立場若透過詐欺罪連貫的因果構造交互影響，即可能發生過度處罰而使詐欺罪「脫財產犯化」的危險。其次，本文也在理論上分析目前我國學理上各種詐欺罪的財產損害概念，指出受向來學說、實務採用的各種財產損害概念，難以直接作為詐欺罪解釋論之基礎。本文對此主張，可於個別財產說的基礎上，採所謂功能的財產概念進行修正。本文也透過學理上的分析檢討所得，援用被害人因詐欺所為同意、承諾之有效性領域的法益關係錯誤說，並藉此再理解詐欺罪的成立構造。最後，本文歸納上述研究的成果，並以此說明本文所舉各實務案例為總結。

* 投稿日：2019年2月28日；接受刊登日：2019年10月2日。〔責任編輯：黃品瑜〕。

本文為科技部補助專題研究計畫之研究成果（計畫編號：MOST 106-2410-H-194-048-）。本文之初稿曾發表於2018年12月1日由海南大學法學院主辦之海峽兩岸中青年刑法學者高級論壇，感謝當日與談人及與會先進提供的寶貴意見。並且，也感謝兩位匿名審查人對本文提供深入懇切的寶貴學術意見，提高本文的完成度與可讀性。惟文責由筆者自負，乃屬當然。

** 國立中正大學法律學系副教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/41011002.pdf>。



關鍵詞：錯誤、法益關係錯誤說、詐術、財產損害、個別財產、整體財產、交易目的。

目次

壹、前言	參、詐欺罪處罰擴張的限定解釋可能性之探求
貳、我國詐欺罪實務的考察	一、詐欺罪之財產損害概念的再思考
一、我國詐欺罪實務中被害人因詐術所生錯誤的考察	二、詐欺罪被害人錯誤內容之限定可能性的探求
二、我國詐欺罪實務中詐欺罪財產損害的考察	三、詐欺罪構造的理解
三、分析與檢討	肆、結論

壹、前言

我國刑法第339條第1項之詐欺罪基本規定是：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」。在這樣的規定下，我國刑法學界在詐欺罪的領域，一般均認為詐欺罪的成立構造上，需以被害人因行為人所施行的詐術發生了錯誤，再基於錯誤處分財產，將財物交付行為人或第三人，因此受有財產上損害為構造¹。在這樣的規定之下，從行為人的詐術行使至財產損害的連

1 參照：林鈺雄，論詐欺罪之施用詐術，臺大法學論叢，32卷3期，頁119-121（2003年）；林山田，刑法各罪論（上冊），5版，頁83、447（2006年）；吳耀宗，詐欺罪詐術行使之解析，月旦法學雜誌，163期，頁51（2008年）；廖晉賦，「懷疑」是否構成詐欺罪之「陷於錯誤」——以「被害者學理論」為中心，刑事法雜誌，53卷3期，頁101（2009年）；王效文，職棒比賽放水詐賭的刑事責任，月旦法學教室，88期，頁91-92（2010年）；曾淑瑜，騙人不一定成

貫的因果關係固然成為詐欺罪歸責的基礎，但是詐欺罪具體處罰範圍，仍需進一步透過對於詐欺罪所保護的財產法益的範圍，乃至於構成要件要素的解析，才能界定。

因為詐欺罪所保護的財產法益，體現於財產損害的概念上，所以從理論的觀點來看，詐欺罪的財產損害概念之內涵如何，將對同罪的處罰範圍產生直接的影響。

如後所述，關於詐欺罪的財產損害，我國學說與實務目前主要的見解，有所謂個別的財產概念（或個別的財產說），與整體的財產概念（或整體的財產說）。前者認為個別財物的交付本身即為損害之所在，後者原則上透過交付財物前後的被害人整體資產有無減損確認有無詐欺罪之損害，但是在整體資產並未減損的情況，還有可能將被害人交付財產之主觀目的是否達成納入判斷有無財產損害的考慮中。

然而，關於個別的財產概念，考慮到詐欺罪的被害人在經濟交易中所抱持的目的可能相當多樣，並且考慮到詐欺罪的被害人所進行的給付未必均有對待給付，也可能有片面的贈與等情形，形式地貫徹此一見解，無異於將各種被害人的主觀交易目的納入考慮，對詐欺罪的成立難以限定。另一方面，整體的財產概念在有對待給付時，固然可能相當程度將詐欺罪的成立限定於對待給付不相當的情形，但是在對待給付相當時同樣地透過考慮被害人要達成的主觀交易目的以肯定詐欺罪。倘若對被害人要達到的交易目的並無任何限定，則整體財產概念也將同樣面對詐欺罪成立範圍難以限定的問題。此一問題的重要性在於，倘若對財產損害概念無所界定，那麼

立詐欺罪，台灣法學雜誌，225期，頁161（2013年）；甘添貴，刑法各論（上冊），修訂4版，頁311（2014年）；陳子平，刑法各論（上冊），3版，頁555（2017年）；許澤天，刑法各論（一）：財產法益篇，2版，頁106（2018年）；古承宗，刑法分則：財產犯罪篇，頁189（2018年）；盧映潔，刑法分則新論，修訂13版，頁739-740（2018年）等參照。

不僅是與財產有關的要素，即使是與財產無關的人際關係甚至國家的政策等考慮均會成為肯定財產損害的基礎。如此一來，即可能發生為了與財產無關之目的使用詐欺罪進行處罰，導致詐欺罪處罰範圍過度擴張的危險。

這一個問題在詐欺罪被害人因詐術所生之錯誤內容的解釋上，同樣會出現。理由在於，在目前我國的學理上，對於詐術的解釋著重在與事實不符的特徵，除此之外並無太多限制²。倘若如此，在被害人因此種詐術所生的錯誤內容也無限定時，上述人際關係的考慮，或者國家政策的考慮等要素同樣可能成為被害人發生錯誤之所在。如此一來，這些未必與財產有必然關連的事項也將隨著詐欺罪的連貫因果關係構造，成為詐欺罪處罰的基礎。在此意義下，同樣地可能發生作為財產犯罪的詐欺罪用於非財產之目的，導致處罰過度擴張的疑慮。

更進一步，因為詐欺罪的成立構造上有連貫的因果關係，所以上述的兩個問題更可能同時在詐欺罪的成立構造中發生作用而交互影響。因此，究竟如何一方面在上述的條文文義下充分保護法益，一方面讓詐欺罪的處罰範圍合理化，即成為解釋論上的重要問題。另一方面，此一理論問題倘若在實務上也有可能發生，則以目前的學理發展為前提，嘗試提出對此一問題的可能解釋方向，對於實際上形成處罰界線的實務而言也有重要的實踐意義。

基於這樣的問題意識，本文將以詐欺罪的財產損害以及被害人

2 我國學說一般認為(1)在可作為詐術內容的事項上，以過去、現在或未來之事實為限、(2)不限表現於外的事實，即使是內心的事實，例如支付的意願等，也可以成為詐術的內容、(3)詐術的手段不以作為為限，可以是不作為，並且不論明示或默示均無不可。參照：林鈺雄(註1)，頁121-127、132；吳耀宗(註1)，頁52-55、58-59；林山田(註1)，頁452-455；甘添貴(註1)，頁314-345；陳子平(註1)，頁558-560；許澤天(註1)，頁109、111、114-115；古承宗(註1)，頁195-203；盧映潔(註1)，頁740-743。

因詐術所生錯誤之內容為素材，考察我國詐欺罪實務的現況，並透過理論的分析掌握我國實務中隱含的詐欺罪擴張處罰的危險所在（貳、）。其次，本文也將透過理論的檢討，探求可能作為解釋論基礎的詐欺罪財產損害概念。並且，考慮到詐欺罪構造的核心在於被害人基於錯誤而同意交付財物，則可認為事實上詐欺罪與其他犯罪中被害人因錯誤而基於其意思為法益處分的情形有相同的構造³，因此本文也將透過探討刑法總論中被害人因錯誤而為同意或承諾領域的理論，嘗試探求可能限定詐欺罪被害人所生錯誤內容的解釋論⁴。同時以本文對於詐欺罪財產損害及被害人之錯誤內容的理解為基礎，嘗試整理詐欺罪的成立構造（參、）。最後，本文將歸納上述考察的成果，並透過對於我國實務案例的說明，嘗試具體化詐欺罪的處罰界限（肆、）。

貳、我國詐欺罪實務的考察

本文此部分內容中，將透過考察最近有關詐欺罪的法院實務裁判，一方面掌握目前我國詐欺罪實務中被認為成立詐欺罪的主要類型及處罰界限，另一方面也嘗試透過這樣的考察發現容易導致詐欺罪在處罰範圍上擴張的機制為何。

在此可先說明的是，因為主要涉及的詐欺罪條文是刑法第339條第1項的規定，且考慮到在我國目前的刑事訴訟制度下，同條項之罪依照刑事訴訟法第376條第1項第4款的規定，原則上仍是不得上訴第三審法院之罪，因此以下的內容中作為考察對象的，除一部

³ 參照：佐伯仁志，被害者の錯誤について，神戸法学年報，1号，頁102（1985年）。

⁴ 在此意義下，詐欺罪雖為刑法分則的犯罪，但是其相關的理論問題則有橫跨刑法分則與刑法總則的縱深。

份最高法院判決外，是筆者透過司法院法學資料檢索系統查詢我國高等法院及其各分院的詐欺罪判決後所選出，符合本文著重的觀察角度，亦即有關詐術行使及被害人所生錯誤，以及有關對待給付或勞務的行為態樣之裁判⁵。如此一來，應該可以相當程度呈現目前我國詐欺罪刑事實務的現況。

一、我國詐欺罪實務中被害人因詐術所生錯誤的考察

本文在此將先透過對於我國實務中，被害人因詐術所生之錯誤內容成為問題的實務事例進行考察，藉以掌握我國實務的狀況。考慮到詐欺罪的被害人可能在與行為人進行有對待給付的交易中交付財物而受害，也可能是單方面地因自己交付財物的行為受害，因此以下的考察，也先將「對待給付型」與「片面贈與型」加以分類後，再細就其中的各種類型詳細觀察我國實務的現況，作為進一步分析我國實務中隱含之詐欺罪處罰擴張可能性的基礎。

(一) 對待給付型

1. 投資、借款型

在我國的詐欺罪實務中，投資、借款等經濟行為中經常成為問題的行為態樣主要可見於（1）向投資人宣稱有高利潤（或高利息）的投資標的，但是在投資人相信並出資後，並未實際用於所宣稱之投資項目；（2）向相對人即被害人提出借款理由，但是在取得被害人所貸與之款項後，拒不還款的情形。

5 另外可以補充說明的是，因為本文此部分的重點在於探究詐欺罪的處罰範圍的界限，所以例如①詐騙集團謊稱檢察官、警官等司法人員或健保局官員詐騙民眾匯款；②詐騙集團謊稱中獎並以支付手續費名義騙取民眾匯款；③使用他人名義信用卡的詐欺；④自始無支付意願仍要求廠商供貨；⑤自始無出賣意思但仍與他人簽訂買賣契約等詐欺罪常見的類型，由於在詐欺罪的成立上較無疑問，因此在本文中只能割愛。

屬於（1）的情形可舉【事例1】臺灣高等法院101年度金上重訴字第53號刑事判決與【事例2】臺灣高等法院臺中分院93年度上易字第254號刑事判決為例。

【事例1】臺灣高等法院101年度金上重訴字第53號刑事判決的事實關係如下：

A為甲證券公司營業員兼任乙外國銀行之獨立資產管理人，與業務上有往來且由乙銀行投資設立之丙公司副總裁即B、不動產業者即C共同投資土地，約定由C取得投資標的即丁地之土地所有權之後，因集資等事項進行不順利，購買土地也尚需尾款，A乃欲引進其客戶即被害人X存放於乙銀行香港分行帳戶之資金解決，乃與B、C共謀後，由B透過外商在境外設立戊基金，該基金之目的完全僅在投資丁土地，並由不知情的A之配偶D擔任人頭負責人，再製作基金條款及私募說明書，向X宣稱，戊基金是以投資日本及新加坡等亞洲都會區之不動產買賣、開發為目的，並向投資人發行受益證券的不動產信託基金，風險極低，可期獲利。B也從旁協助說明，X乃誤認戊基金為是一般由專業經理人所管理，且投資標的為亞洲都會區不動產之優質基金，因此同意投資，並於簽署相關文件後，將存款美金6百萬元分次匯入A所指定之帳戶。A取得該筆款項後，將款項用於返還積欠其他投資丁土地之金主之本息欠款、投資利息，並由C以其中之美金1百萬元完成土地交易，將土地所有權移轉至A、B、C所另外設立之己公司，事後X於收受戊基金受益憑證時，發現該基金董事為A之配偶，心生懷疑，經向B求證質問其基金運作架構與所匯美金6百萬元流向，才知受騙⁶。

針對此一事實關係，法院認為①基金的投資標的於投資理財上，絕對是基金投資人決定是否投資之最重要決策訊息，②本件實

6 此處之事實關係是摘要自臺灣高等法院101年度金上重訴字第53號刑事判決。

際上戊基金之投資標的僅有我國之丁土地，A卻向X宣稱將投資新加坡、日本等外國不動產，藉以隱瞞真實，才使戊陷於錯誤而出資匯款，肯定本件被害人是因錯誤而處分交付財物，受有財產損害等理由，A、B、C三人應負刑法第339條第1項之詐欺罪的共同正犯刑責⁷。

7 參照臺灣高等法院101年度金上訴字第53號刑事判決。屬於這種謊稱投資或投資內容不實類型，肯定詐欺罪成立的類似案件，至少另可舉出：臺灣高等法院臺中分院95年度金上訴字第619號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院97年度上訴字第103號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院99年度上訴字第1983號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院101年度上訴字第1237號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院101年度上訴字第1235號刑事判決、臺灣高等法院95年度上訴字第4736號刑事判決、臺灣高等法院98年度重上更（一）字第226號刑事判決、臺灣高等法院99年度上易字第2675號刑事判決、臺灣高等法院98年度上重更（一）字第39號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院99年度上易字第1640號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院103年度上易字第733號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院103年度上易字第1590號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院101年度上易字第789號刑事判決、臺灣高等法院101年度上訴字第88號刑事判決、臺灣高等法院100年度上訴字第1785號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院100年度上易字第1316號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院101年度上易字第165號刑事判決、臺灣高等法院101年度金上更（一）字第2號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院102年度上易字第216號刑事判決、臺灣高等法院臺南分院102年度上易字第631號刑事判決、臺灣高等法院102年度金上訴字第11號刑事判決、臺灣高等法院102年度上易字第1109號刑事判決、臺灣高等法院103年度上易字第2203號刑事判決、臺灣高等法院102年度金上訴字第59號刑事判決、臺灣高等法院103年度上易字第865號刑事判決、臺灣高等法院103年度上易字第867號刑事判決、臺灣高等法院102年度上易字第1458號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院104年度上易字第1034號刑事判決、臺灣高等法院104年度上易字第1767號刑事判決、臺灣高等法院104年度上易字第1612號刑事判決、臺灣高等法院104年度上訴字第2225號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院104年度上訴字第992號刑事判決、臺灣高等法院臺南分院105年度上易字第301號刑事判決、臺灣高等法院105年度上易字第969號刑事判決、臺灣高等法院105年度上易字第1322號刑事判決、臺灣高等法院105年度上易字第709號刑事判決、臺灣高等法院105年度上易字第2480號刑事判決、臺灣高等法院106年度金上更（一）字第1號刑事判決、臺灣高等法院105年度上重訴字第17號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院105年度上易字第950號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院105年度上易字第366號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院104年度上訴字第1571號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院105年度上訴字第1150號刑事判決、臺灣高等法院106年度金上重訴字第10號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院106年度上易字第509號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院106年度上易字第74號刑事判決。

【事例2】臺灣高等法院臺中分院93年度上易字第254號刑事判決的事實關係如下：

A、B、C分別為甲公司之董事長、業務總監、行政總監，甲公司向乙寶塔公司購買7百個塔位並付清價金後，向被害人X遊說投資靈骨塔，並宣稱預估市場將成倍數成長，風險低、利潤豐厚，公司保證買回，X信其所言，與甲公司負責人即A簽訂靈骨塔位永久使用權買賣契約，購買骨灰盒位、撿骨甕位各50個，總價新臺幣7百萬元，並約定一年半後若X未能出售前開骨灰盒位、撿骨甕位，甲公司將以每座8萬元買回。惟一年半後X欲向A請求依約買回時，甲公司結束營業，A已不知去向，且X轉向B、C請求後，其等雖簽訂協議書願給付2百萬元，實際未為任何給付亦失去音訊⁸。

對此事實關係，X以涉犯詐欺罪嫌，對A、B、C等人提起自訴，主張A等人利用經銷上述塔位之機會，刻意炒作塔位行情，並配合其等誇大不實之市場成長及風險分析，及保證公司以高價買回塔位之不實承諾，令X陷於錯誤，而與之交易。但是法院以①本件X與甲公司之間塔位買賣價格合乎行情、②買回條款係經X與A當場協議簽訂，並非詐術行使、③甲公司並未履行買回之約定，僅係民事上的債務不履行問題等理由，否定詐欺罪的成立，而肯定原審對A、B、C所作成的無罪判決⁹。

至於（2）借款類型的情形，則可舉【事例3】臺灣高等法院高雄分院104年度上易字第181號刑事判決為例。本件檢察官起訴之事

⁸ 此處之事實關係是摘要自臺灣高等法院臺中分院93年度上易字第254號刑事判決。

⁹ 參照：臺灣高等法院臺中分院93年度上易字第254號刑事判決。關於投資靈骨塔的案例，另可參照：葉培靚，因詐術取得被害人同意或承諾有效性的檢討，國立中正大學法律學系研究所碩士論文，頁19-20（2018年）。另外可於此先附帶說明的是，本文以下內容中，於介紹法院所做成之判斷的內容時，為後文分析（貳、三、（一）以下）之便，會將其內容中屬於同種類的各點，賦予同一編號（圓圈內數字），而非單純依照分點的數目依序編號。

實關係如下：

A係址設中國之「甲食品有限公司（下稱甲公司）」之股東，該公司從事肉類食品加工，對外以「烏橋牌」名義進行販售與宣傳，且利用「烏橋牌」與我國肉品知名品牌「黑橋牌」之閩南語發音相同及「黑橋牌公司」總經理即該家族第二代X1與自己姓名相近且年紀相仿等機會，對外常向友人以閩南語表示自己是「黑（烏）橋牌」之「老闆子」，使友人誤以為A係「黑橋牌公司」負責人之子，且A在公開場合聽聞友人以上開頭銜介紹時，明知眾人均已誤認自己係「黑橋牌公司」負責人之子，卻不為澄清甚且默認之，而使該不實事項於友人間流傳。A於2010年間某日，經由不知情之X2以「黑橋牌公司少東」之身分介紹予被害人X3，復介紹予被害人X4，A即以前揭方式使X3、X4就其是黑橋牌公司少東一事陷於錯誤，並據此評估A之債務清償能力。嗣A於2013年3月間與X3一同前往址設菲律賓，由X3擔任業務代理之丙賭場賭博，A明知自己資力不足以清償，仍利用X3誤以為A係「黑橋牌公司」負責人之子之錯誤，向X3借款，並佯稱返回臺灣後可立即清償，致X3借予A相當於新臺幣3千6百萬元之港幣供其賭博。A返臺後，X3要求A清償上開借款時，A又再向X3借相當於新臺幣2千4百萬元之港幣，供其前往丙賭場賭博，X3同意借款，且A當場簽發票面金額均為新臺幣2千萬元之支票3張作為擔保。嗣因A簽發之上開支票3張，屆期均無法給付票款，且避不見面，致告訴人X3受有損害。另外，A因在積欠X3債務的情況下，於2013年4月初某日，向被害人X4表示欲借款新臺幣3千萬元，並提出由自己簽發，票面金額分別為新臺幣1千5百萬元、3百萬元、4百萬元、4百萬元、4百萬元之支票5張以擔保清償，繼而提出自己所有之不動產清單，佯稱該等不動產價值新臺幣2億餘元，可供擔保其借款，被害人X4允諾借款且於2013年4月12日與A簽立「借款清償約定書」並經公證。惟因X3發覺有異，即時察悉A與知名的「黑橋牌公司」毫無關係，且發現A提供予被

害人X4之清單上所列不動產多已設定抵押權或信託，已不足以擔保所借款項之清償，旋即通知被害人X4並阻止其匯款而不遂¹⁰。

對此被訴事實，本件法院調查證據並認定事實後，就X3部分認為，①固然A有使他人誤會自己為知名企業少東之舉動，但是考慮到②本件前往澳門賭場之行為，係X3積極拉攏A前往，並非A自己積極接近X3、③A在澳門賭場所賭金額越多，X3可得之佣金也越多，可知X3貸與A款項與A的身分無必然關連、①A在回臺後再借款的過程，也無提及自己是黑橋牌少東身分或以該身分擔保；就X4部分認為①X4借款與A時從未確認A是否為「黑橋牌公司」負責人之子但仍借款，可見A之身分與是否借款無關、④A也有積極還款的行為等要素，應認為本件A並無以上開吹噓身分背景作為詐欺之手段，從而維持原審關於詐欺罪所為的無罪判決¹¹。

2. 商品瑕疵型

在我國的詐欺罪實務中，買賣交易時，也常因出賣人所提供之商品的瑕疵、缺陷，導致買受人認為受到詐欺而發生涉訟的情形。這種情形，可舉【事例4】臺灣高等法院102年度上易字第396號刑事判決與【事例5】臺灣高等法院104年度上易字第1226號刑事判決為例。

【事例4】臺灣高等法院102年度上易字第396號刑事判決的事實關係如下：

A於1999年8月間購買本件繫爭之建築物，並於2002年移轉所有權至其妻B名下，但實質上關於該建築物之處分等決策仍以A之意見為斷。A明知上述建築物因遭逢1999年之921大地震而損壞，

¹⁰ 此事實關係是整理自臺灣高等法院高雄分院104年度上易字第181號刑事判決。

¹¹ 參照：臺灣高等法院高雄分院104年度上易字第181號刑事判決。關於本件判決的簡要介紹，另可參照：葉培靚（註9），頁21。

嚴重傾斜，且經改制前臺北縣政府認定為黃標危險建築物，仍於2009年間透過B委託甲不動產經紀有限公司出售此一建物。其後，不知情之業務員C介紹被害人X購買本件建築物，因X有意購買，買賣雙方乃於2010年4月6日在甲公司簽立不動產買賣契約書。於同日簽約之際，在甲公司會議室內，對X於簽約前大聲提問本案建物是否為凶宅、結構有無問題、有無傾斜等事項，A均故意隱匿避不答，致X陷於錯誤，向本案建物登記名義人B以新臺幣1千零70萬元價格購入本案建物，並簽立不動產買賣契約書，X支付買賣價金完畢後入住未久，經鄰居告知本案建物業經臺北縣政府列管為危險建物，始知受騙。

對此事實關係，本件法院認為A雖非所有權人，但是就本案建物購買時之屋況、本案建物是否出售、託售後與仲介公司之議價、最後出售之價格為何等事項均知悉、參與且有決定權，為本案建物之實際所有權人，B僅為借名登記之名義所有權人，並且①X於本案建物買賣契約簽訂時即已當場主動就本案建物是否為凶宅、結構有無問題、有無傾斜等個別事項具體提問、②A仍避而不答，是故意隱瞞本案建物係有傾斜之黃標危險建物，因此可認為③X因此陷於錯誤以新臺幣1千零70萬元之代價購入本案建物，從而可肯定A之行為成立刑法第339條第1項之詐欺罪¹²。

【事例5】臺灣高等法院104年度上易字第1226號刑事判決的事實關係如下：

A與友人B以新臺幣2百萬元於「我國凶宅」網站購得C等人共有，且註明「凶宅燒炭自殺」字樣拋售之本件繫爭房屋後，故意隱匿凶宅訊息，並在簽訂買賣契約時，於「標的現況說明書」第18項「本建築改良物專有部分（含增改建）於賣方產權持有期間是否曾

12 參照：臺灣高等法院102年度上易字第396號刑事判決。

發生凶殺或自殺致死之情事？」之部分勾選「否」，且於同項「備註說明」欄內未為任何記載，致使被害人X因不知該屋是凶宅，同意以新臺幣4百萬元之市價購買，並簽約付款且辦理移轉所有權登記完畢，嗣後X經人告知甲屋為凶宅，始知受騙¹³。

對此事實關係，本件法院認為①就我國一般社會大眾而言，凶宅因素雖非造成房屋之物理性損害，但在能否安寧居住的層面將生心理平穩上的影響，因此凶宅因素是一種使房屋交易價格顯著低落，造成經濟價值減損而影響市場價格的物之瑕疵，A對此有告知X之義務；②A於購入本件繫爭房屋後3個月內即出售，即使上述「標的現況說明書」之問題係僅就賣方產權持有期間為標的，但是仍不能因此認為A可免除告知本件繫爭房屋為凶宅之義務；③A隱瞞凶宅之事實而以市價出售房屋與X，使X陷於錯誤支付價金，應成立刑法第339條第1項之詐欺罪¹⁴。

3. 產品成分不實型

在我國的詐欺罪實務中，買賣交易時，也常因出賣人所提供之商品並無所宣稱之成分或者功能，導致買受人認為受到詐欺而發生涉訟的情形。這種情形，可舉【事例6】智慧財產法院105年度刑智上訴字第1號刑事判決與【事例7】臺灣高等法院臺南分院104年度

¹³ 此處事實關係是摘要自臺灣高等法院104年度上易字第1226號刑事判決。

¹⁴ 參照：臺灣高等法院104年度上易字第1226號刑事判決。與上述【事例4】【事例5】同屬不動產交易且法院也肯定詐欺罪成立的案例，例如：臺灣高等法院臺中分院89年度上易字第964號刑事判決（隱瞞供客人加油之油為性質不明之油品）、臺灣高等法院臺中分院94年度上訴字第1579號刑事判決（隱瞞出賣之機具取得來源不合法）、臺灣高等法院臺南分院98年度上訴字第196號刑事判決（隱瞞出賣之物為贓物）、臺灣高等法院102年度上易字第2754號刑事判決（隱瞞建築物傾斜）、臺灣高等法院臺中分院103年度上易字第1304號刑事判決（隱瞞出賣之物為贓物）、臺灣高等法院104年度上訴字第2584號刑事判決（隱瞞建築物為海砂屋且曾發生氣爆）、臺灣高等法院105年度上易字第1473號刑事判決（出賣汽車時調降汽車行車公里數）、臺灣高等法院106年度上更(一)字第36號刑事判決（隱瞞出賣之物為贓物）等參照。

上訴字第350號刑事判決為例。

【事例6】智慧財產法院105年度刑智上訴字第1號刑事判決的事實關係如下：

A係址設新北市之「甲石膏化工有限公司」(下稱甲公司)之負責人，所營事業項目包含食品添加物批發業、食品添加物零售業，乃製造及販賣食品添加物之公司，自2013年起，自A擔任實際負責人而址設中國湖北省之「乙石膏化工有限公司」(下稱乙公司)進口乙公司所生產，實際上尚不得做為食品添加物之無水硫酸鈣(CaSO_4)，於包裝袋上記載：「高級石膏、Calcium Sulfate、用途：豆花豆腐用、食品制造用、釀造用」，以及甲、乙公司名稱等，假冒為經公告許可之食品添加物二水硫酸鈣，且於包裝袋正面虛偽標示原行政院衛生署(現已改制為行政院衛生福利部)核發之食品添加物許可證字號，反面虛偽標示：「本產品可使用於各類食品、使用限制：限於食品製造或加工等」使數家下游廠商與不特定之多數消費者陷於錯誤，向甲公司購買上開假冒及虛偽標記之硫酸鈣產品，並用以添加至豆花等食品中，販售金額合計為新臺幣14萬2千5百95元¹⁵。

對此事實關係，法院認為①本件A所販賣的產品為尚未經過政府公告許可之無水硫酸鈣，但仍在包裝上偽稱是經公告許可之二水硫酸鈣，②依本件各被害人陳述，倘若知悉所購買之產品並未經中央主管機關許可，應不會向甲公司購買，因此應認為本件A之行為使被害人等陷於錯誤而交付財物，成立刑法第339條第1項之詐欺罪¹⁶。

¹⁵ 此處事實關係是摘要自智慧財產法院105年度刑智上訴字第1號刑事判決。

¹⁶ 參照：智慧財產法院105年度刑智上訴字第1號刑事判決。與此判決相類的判決，另可參照：臺灣高等法院臺南分院99年度上訴字第439號刑事判決(以等級較低之藥品混充等級較高之藥品)、臺灣高等法院高雄分院104年度上易字第346號刑事判決(以路邊攤所購得之器物混充來自中國的高級宗教法器)、智慧

【事例7】臺灣高等法院臺南分院104年度上訴字第350號刑事判決的事實關係如下：

A為自2001年間經營址設臺南市之豆芽菜生產製造工廠，A為期豆芽菜經漂白賣相較佳、防止氧化、增加保存期限，向化工廠購買「低亞硫酸鈉（Sodium Hydrosulfite）」（俗稱保險粉，以下亦簡稱保險粉）使用。A知悉衛生福利部雖公告「低亞硫酸鈉（Sodium Hydrosulfite）」（俗稱保險粉，以下亦簡稱保險粉）可作為食品添加物以抗氧化、漂白，並公告作為漂白劑可用於金針乾製品、杏乾、白葡萄乾、動物膠、脫水蔬菜及其他脫水水果、糖蜜及糖飴等，如作為抗氧化劑可用於麥芽飲料、果醬、果凍、果皮凍及水果派餡等，但是其公告範圍內並無豆芽菜。A與員工B共同使用該保險粉浸泡成熟之豆芽菜，並以平均日產2千台斤之數量，以每台斤平均4元8角之價格，透過不知情之員工、司機協助整理、裝載、運送、販賣予高雄市、臺南市地區傳統市場或黃昏市場等攤商，其中攤商再以轉賣方式供消費大眾食用，平均每日販賣所得新臺幣9千6百元¹⁷。

對此事實關係，法院則認為①豆芽菜作為生鮮蔬菜直接販賣時皆無容器或外包裝，而在行為當時的法令規定下，立法者並未就無使用容器或外包裝生鮮蔬菜之散裝販賣規定必須標示食品添加物之義務；②本件A之販賣方式均為出貨後散裝販售，因此並無法律上必須告知消費者的義務，從而並無行使詐術之情形；③本件A使用之保險粉是可用於漂白與抗氧化的合法食品添加物，即使依照行為時食品安全衛生管理法第49條第1項、同法第15條第1項第10款可認

財產法院103年度刑智上易字第13號刑事判決（在生產販售之油品中攪入成分外之物質、攪入未准許合法添加之色素、以低價油混充高價油）等。

17 此處事實關係是摘要自臺灣高等法院臺南分院104年度上訴字第350號刑事判決。

為成立食品安全衛生管理法之罪¹⁸，但是並不能以此認為A當然成立詐欺罪，從而對檢察官起訴刑法第339條第1項之詐欺罪部分認為A無罪¹⁹。

4. 身分資格不符型

有關於身分資格不符的情況，在我國的詐欺罪實務中，主要可見於（1）行為人冒充自己具有律師或醫師等專門職業技術人員之資格，為被害人進行專門職業上的服務，同時收取費用的情形，以及（2）民意代表違反不得具有雙重國籍的規定，隱瞞自己所具有之外國國籍宣示就任，同時領取民意代表的薪資與相關業務費用的情形。其中，（2）的情形，在我國刑法學界一般也稱為「巧取公職」型的詐欺²⁰。

（1）冒充專門技術人員型

冒充專門技術人員的類型，可以舉【事例8】臺灣高等法院106年度上易字第1872號刑事判決為例。本件判決的事實關係如下：

A於社群網站臉書上認識X，且在與X之談話訊息中，得知X之妹Y因車禍與他人發生民事、刑事訴訟，同時欲向Y所任職之甲清潔服務股份有限公司（以下簡稱甲公司）請求因勞資糾紛所生的損

18 本件被告行為時食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定：「食品或食品添加物有下列情形之一者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列：……十、添加未經中央主管機關許可之添加物。」

同法第49條第1項規定：「有第十五條第一項第七款、第十款行為者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣八百萬元以下罰金。」

19 參照：臺灣高等法院臺南分院104年度上訴字第350號刑事判決。

20 此一用語，可參照：薛智仁，巧取公職之詐欺罪責——評臺北地方法院九十八年度金重易字第9號及臺灣高等法院九十九年度上易字第2號刑事判決，月旦法學雜誌，212期，頁203（2013年）。另亦可參照：許恒達，公職詐欺與財產損害——以臺灣高等法院九十九年度上易字第2號刑事判決為討論中心，月旦法學雜誌，217期，頁22（2013年）。

害賠償，A除提供意見外，對X詢問是否為律師時，不否認自己為律師，且進一步接受X委任，且向X索取新臺幣16萬元費用，X也依約匯款給A。其後，A即就上述Y所涉及之各案件，撰寫勞保糾紛告訴聲明狀、我國新北法院刑事庭附帶民事告訴狀、我國新北法院刑事暨民事告訴聲明補充狀。A並於其後向Y所涉及之勞資糾紛之甲公司經理Z，以Y之律師之名義邀約見面，並於見面時談及Y之糾紛，A並當場提出前開我國新北法院刑事暨民事告訴聲明補充狀予Z，以此方式辦理訴訟，Z心生懷疑後報警處理始查獲上述情節²¹。

對此事實關係，法院考慮①A並非律師，卻於被害人X詢問是否為律師時，不明確否認、②被害人X因此相信A為律師，委任A並提供費用與A，A也提領該筆費用花用，是將該筆費用作為報酬，因此認為A之行為除成立律師法第48條之罪以外，另成立刑法第339條第1項之詐欺罪²²。

（2）民意代表隱瞞雙重國籍巧取公職型

至於民意代表隱瞞其雙重國籍身分，宣示就任並領取薪資及其他業務上費用之情形，則可以舉【事例9】最高法院100年度台上字第5985號刑事判決為例。本件判決的事實關係如下：

A為1990年間取得美國籍之我國籍人民，在未辦理放棄美國國籍之前提下，即投入政治選舉，並於1994年至2004年間，先後當選臺北市議會第7屆市議員，及第4、5、6屆立法委員。A雖明知依當時公職人員選舉罷免法第67條之1規定，當選公職之人須於就職前放棄外國國籍，否則當選即為無效，但仍未依該規定放棄美國籍且仍就任上開各屆議員與立法委員職務，並於就任上開臺北市議員及第5屆立法委員後，於填載市議員個人資料表及立法委員人事登記

21 此一事實關係是摘要自臺灣臺北地方法院106年度易字第150號刑事判決。

22 參照：臺灣高等法院106年度上易字第1872號刑事判決。

表時，刻意隱匿其有美國國籍，不予填載。且被告再於就任上開第4與第6屆立法委員後，於立法委員人事登記表「有無其他國籍」欄位，分別虛偽申報為「無」，由立法院承辦人員以「編列」之方式代替「登載」予以編列造冊，其後經檢察官偵查後認為A之上開行為致臺北市議會及立法院相關業務單位承辦人員陷於錯誤，按月支付歲公費等費用，其另每年向立法院請領出國補助，而分別詐領新臺幣（下同）2千2百68萬2千6百41元、2千5百99萬8千7百90元、2千6百89萬4千8百53元、2千7百20萬1千7百52元，乃依刑法第214條使公務員登載不實罪與同法第339條第1項之詐欺取財罪將A提起公訴²³。

對於詐欺罪部份的事實，本件第二審法院認為①A於受主管機關撤銷或解除其職務前仍有公職身分、②A既仍有市議員與立法委員身分，則其支領相關費用係有法律上正當權源，是其執行職務之實質對價，並非不法取得、③A於受撤銷或解除職務前，所支領之相關費用與其執行職務之間，具有實質對價關係，因此撤銷原審的有罪判決，改判被告無罪。檢察官雖對原判決上訴，但如前所述，刑法第339條第1項之罪依照刑事訴訟法規定不得上訴第三審，因此最高法院也駁回檢察官之上訴使本件確定²⁴。

（二）片面贈與型

1. 感情利用型

以戀愛感情或者將來結婚為由，使交往相對人單方面地提供財物的情形，可舉【事例10】臺灣高等法院101年度上易字第472號刑事判決為例。本件判決的事實關係如下：

²³ 參照：最高法院100年度台上字第5985號刑事判決。

²⁴ 同前註。與本件類似的裁判，例如：臺灣高等法院高雄分院101年度上易字第413號刑事判決（高雄市議員隱瞞美國國籍宣誓就職）。

A為酒店坐檯小姐，結識前來酒店消費之酒客X，見X有追求愛慕之意且有相當資力，乃藉口若X願支付健保費、家用、買斷費等各項名目，將與X交往、結婚。X相信A所言，乃先後交付A健保費新臺幣20萬元、清償A經紀公司之欠款新臺幣69萬元、結婚前提出供A之父在婚後作為家用之新臺幣1百零4萬8千元、積欠經紀公司之尾款新臺幣50萬元。然而A於收受最後一筆50萬元借款後，即避不見面，至約定清償日期亦未與X聯絡清償債務事宜，X即報警處理，經警察循線查知上情²⁵。

對此事實關係，法院以①本件A向X要求提供款項時所使用之理由經查均為虛構、②X是誤以為A真心與其交往，甚至有要與其結婚之真意，始交付A大量金錢為理由，肯定刑法第339條第1項詐欺罪之成立²⁶。

2. 慈善捐款型

訛稱用途為慈善捐款，使人交付財物之情形，可舉【事例11】

25 此處之事實關係是摘要自臺灣高等法院101年度上易字第472號刑事判決。

26 參照：臺灣高等法院101年度上易字第472號刑事判決。與本件類似，以感情為基礎要求相對人交付財物，且法院認為成立詐欺罪的案例，另可參照：臺灣高等法院高雄分院99年度上易字第358號刑事判決（向交往之女友騙取提供信用卡、並且要其為自己辦理貸款）、臺灣高等法院高雄分院99年度上訴字第1026號刑事判決（以結婚為由要相對人交付現金、為其出賣不動產並交付賣得價金等）、臺灣高等法院100年度上易字第92號刑事判決（以結婚為由騙取被害人交付金錢）、臺灣高等法院101年度上易字第2389號刑事判決（以Call客秘書打電話給被害人並透過聊天等方式建立友誼，再虛構理由要被害人為其支付各種費用）、臺灣高等法院103年度上易字第2368號刑事判決（利用在酒店之客人對自己之好感，要其借款但不返還）、臺灣高等法院臺中分院99年度上易字第1574號刑事判決（隱瞞已婚身分且謊稱要與被害人結婚，要被害人提供信用卡供消費、或支付違約金、或借款）、臺灣高等法院臺中分院102年度上易字第1299號刑事判決（以欲和被害人結婚為由要被害人支付各種款項）、臺灣高等法院臺中分院105年度上易字第967號刑事判決（將自己女友介紹給被害人，假意與被害人交往，再使被害人為其購買名牌皮件或交付金錢）。上述各判決中，關於臺灣高等法院101年度上易字第2389號刑事判決的簡要介紹，可參照：葉培艷（註9），頁23。

臺灣高等法院89年度上易字第1236號刑事判決為例。本件判決的事實關係如下：

A於1999年9月21日的「921大地震」後，見全國上下投入災後搶救與賑濟，乃於1999年10月9日上午11時30分許，持其所有之募款竹籃一只，其上並有「九二一震災愛心慈善捐款」之字句，在人潮往來頻繁之臺北市街頭連續向路人以賑災名義募款，致使X1、X2、X3等人陷於錯誤先後交付新臺幣10元、1百元、20元予A供賑災款項之用。嗣經X1察覺有異報警後，乃由警察當場將A逮捕²⁷。

對此事實關係，法院考慮①A於街頭募款行為時，並無有向特定團體或單位捐款之計畫、②A並未出具單據給捐款人、③A於募款時在募款籃內放置自己金錢，製造已經有多人捐款之假象等要素，認為被告之行為成立刑法第339條第1項之詐欺罪²⁸。

二、我國詐欺罪實務中詐欺罪財產損害的考察

在筆者所蒐集的裁判範圍內，我國詐欺罪實務的大多數裁判中，法院並不在詐欺罪的成立要件中檢討被害人是否有財產損害，而是在量刑之中提及被害人受有財產損害，並且以其損害的多少作為量刑輕重的考慮要素之一²⁹。

不過，以筆者所蒐集範圍內的裁判而言，關於詐欺罪的財產損害概念，仍有一定數量的我國實務裁判，在犯罪成立與否的判斷中

27 此處之事實關係是整理自臺灣高等法院89年度上易字第1236號刑事判決。

28 參照：臺灣高等法院89年度上易字第1236號刑事判決。與本件相類似的判決，可參照：臺灣高等法院96年度上易字第1847號刑事判決（向被害人謊稱中獎，但需先匯款至慈善捐款帳戶抵稅）、臺灣高等法院花蓮分院98年度上易字第73號刑事判決（向被害人謊稱中獎，但需先匯款至慈善捐款帳戶，被害人因此依指示匯款）。

29 關於此點，可從筆者利用司法院法學資料檢索系統，以「詐欺」與「財產損害」為關鍵字查詢至2017年為止的裁判後，至少有612筆裁判，而其中有在詐欺罪成立與否的論罪時提及被害人財產損害者，僅有42筆的狀況窺知。

曾經表達法律上的判斷立場。這樣的判斷立場主要有兩種：第一種是採取所謂的「個別的財產概念」之立場，認為被害人所交付的個別財物本身即是財產上損害者；第二種則是採取所謂的「整體的財產概念」之立場，認為需比較被害人交付財物前、後的財產狀態（即依照所謂的「結算原則」³⁰），如有減少時，才認為有財產上損害，但是當被害人交付財物前、後的財產狀態價值相當的情形，則進一步考慮被害人進行交易的主觀目的，在被害人的主觀交易目的沒有達成時，肯定詐欺罪成立的餘地³¹。採取第一種立場的實務裁判，可以舉本文前述的【事例1】臺灣高等法院101年度金上重訴字第53號刑事判決與【事例12】智慧財產法院105年度刑智上易字第38號刑事判決為例，至於採取第二種立場的實務裁判，則可以舉本文前述的【事例7】臺灣高等法院臺南分院104年度上訴字第350號刑事判決，以及【事例13】臺灣高等法院104年度上訴字第2584號刑事判決為例。

（一）採取個別的財產概念的實務事例

在上述【事例1】之中，就詐欺罪是否成立的客觀面，法院依序檢驗行為人「A有無施用詐術？」「被害人X有無受有財產損害？」等問題。關於前者，如同本文前述³²，法院經認定事實後認為答案為肯定。關於後者，對於被告主張其所提出之投資標的即土

³⁰ 參照：許恒達（註20），頁20。

³¹ 當然，在我國刑法學界也有透過援用財產犯罪的基本理論中的財產概念，亦即所謂的純法律的財產概念、純粹經濟的財產概念，以及法律經濟的中介財產概念來探討詐欺罪的財產損害之途徑（例如：林東茂，詐欺罪的財產損害，中央警察大學法學論集，3期，頁199-209（1998年）；林山田（註1），頁459等參照）。然而，因為考慮到（1）此三說對立的核心，實質上應在於是否僅有法律上承認為權利者才能成為刑法上的財產？並且（2）對於本文所舉的各種實務案例，此種檢討角度對於詐欺罪的財產損害的具體界限之界定所能發揮的功能較不明顯，因此本文即不將此種途徑納入探討的範圍。關於財產犯的財產概念的詳細研究，另可參照：林幹人，財產犯の保護法益，頁13-176（1984年）。

³² 參照：本文貳、一、（一）1.之說明。

地價值相當美金6百萬元之抗辯，法院則是以下述理由加以駁斥。

法院首先引用最高法院判例就詐欺罪一般構造所為的說明「刑法第339條第1項詐欺罪之成立，以意圖為自己或第三人不法所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付為要件。故加害者如有不法取得財物之意思，實施詐欺行為，被害者因此行為陷於錯誤而為財產上之處分，受其損害，即應構成該罪」後，提出了以下的大前提作為判斷被害人是否受有財產損害之基準：「詐欺罪構成要件之『財產損害』，學理上固有多方爭論，但就我國立法及實務觀察，我國立法及司法實務上，應係採取保護個別財產之取向。換言之，只要被害人交付其財物，就包含了財產減損而發生損害之概念，並不考慮整體財產是否因此受損」（粗體字為筆者所強調）。對於本件之事實關係，法院認為被害人已經確實將美金6百萬元匯款至A指定帳戶，受有財產損害³³。

上述【事例12】智慧財產法院105年度刑智上易字第38號刑事判決的事實關係如下：

A為甲公司之董事長，另擔任乙公司、丙公司及丁公司、戊公司之董事長。B為丙公司之總經理，C、D受A指示綜理丙公司之經營方向與策略。為降低調和油之生產成本，A等將棕櫚油比例提高至近100%，改以深色瓶身掩飾棕櫚油易結晶之事實，再以橄欖

33 參照：臺灣高等法院101年度金上重訴字第53號刑事判決。本件法院另於傍論交代，即使採取整體財產說，也不能僅從客觀面考慮被害人所得之給付的經濟價值與所交付之財物的經濟價值是否相當，就判斷被害人是否受有財產損害，必須進一步考慮被害人主觀的目的，當被害人主觀之目的無法達成時（例如要買名錶卻以相當之價格買到假錶），仍應該認為其受有財產上損害，而本件被害人X既然是要以其所支付之資金投資大樓開發案，並非本件之農地，則即使被告A將其資金投資於相當之農地，仍應認為X之目的無法達成，從其主觀標準下，仍應認為整體財產受有損害。另外，僅提及交付物品即指出被害人受有財產損害的判決，例如：臺灣高等法院臺中分院102年度上易字第31號刑事判決參照。

油、葡萄籽油為品名之高品質調和油名義販賣，並標示「添加葡萄籽精華……」；「獨家技術結合進口頂級橄欖油調理優點」；「獨家技術結合特賞玄米油及歐洲頂級橄欖油調理優點」；「精選歐洲進口葡萄籽油，以特級黃豆油調和而成」；「萃取西班牙橄欖油之營養精華，以理想比例與美國特選黃豆油調合」；「萃取歐洲精選進口頂級橄欖油精華，以獨家配方黃金比例與特選黃豆油調合」；「萃取歐洲頂級葡萄籽油精華，以黃金比例與特選黃豆油調合」；「獨家技術結合進口頂級葡萄籽油調理優點」；「以高單元不飽和棕櫚果實油、精製黃豆油、橄欖油調和而成」；「以高單元不飽和棕櫚果實油、精製黃豆油、葡萄籽油調和而成」；「萃取歐洲進口橄欖油與葡萄籽油，並以獨家理想比例調合而成」等不實內容，使一般消費者見外包裝誤以為係營養價值較高之油品而購買，藉此取得販賣該調和油之貨款共計新臺幣6千1百11萬8千零49元³⁴。

對此事實關係，法院除認定本件之被害人倘若知道事實即不會購買本件油品，是因詐術而發生錯誤外，關於被害人是否受有財產損害之問題，針對被告所提其所售油品之售價相當之主張，法院則先指出：「**刑法第339條第1項之詐欺取財罪**，依其條文內容，以被害人因受他人詐術而將本人或第三人之財物交付即為已足，至於被害人整體之財產狀況有無變動當非所問，如行為人已具備為自己或第三人不法所有之意圖、實施詐術及被害人因行為人之詐術陷於錯誤而交付財物等要件，即構成詐欺取財罪，並不以取得不相當對價之財物為限，縱使行為人取得被害人之財物係採取交易方式，且其亦付出相當代價，倘被害人係因受其詐術欺瞞致陷於錯誤，始決意與其交易而交付財物，行為人因施用詐術而取得交易機會，進而進行交易而取得對方財物之行為，亦該當詐欺取財罪之構成要件」（粗體字為筆者所強調），並且認為本件消費者一旦知悉被告等人加

34 此處之事實關係是摘要自智慧財產法院105年度刑智上易字第38號刑事判決。

入於油品之成分可能在健康上發生風險，即使售價再低、再相當，也不會願意購買本件油品，從而仍應認為受有財產損害³⁵。

(二) 採取整體財產概念的實務事例

上述【事例7】臺灣高等法院臺南分院104年度上訴字第350號刑事判決中，就購買本件浸泡過保險粉之豆芽菜的顧客是否受有財產損害的問題，法院指出A所為「係添加未經許可之食品添加物於食品而販賣，實際上仍為一般買賣行為，消費者雖有交付金錢外，亦有獲取相當對價之豆芽菜，故被告A為縱有違反食品衛生管理法之規定，但實與刑法第339條第1項之施用詐術，而使被詐欺之一方陷於錯誤，進而交付財物之詐欺取財犯行，尚有未合」(粗體字為筆者所強調)。亦即法院係因消費者所購買之豆芽菜價格仍屬相當，否定了其財產損害的存在乃至詐欺罪的成立。

上述【事例13】臺灣高等法院104年度上訴字第2584號刑事判決的事實關係如下：

A所有之房屋為海砂屋，且因其房屋之鋼筋嚴重鏽蝕，部分已鏽斷，2013年1月間曾發生混凝土塊狀剝落，砸中2樓房屋瓦斯管、水管引發氣爆之事故，已經由新北市政府工務局函知居於該棟房屋之各樓層所有權人，明令該棟房屋各樓層陽台立即停止使用並進行修復補強。A在未就該陽台所在區域之室內樓板進行修復補強之情形下，就於同年5月間委託不動產仲介公司之副店長B出售上述房屋及所坐落之土地。A於委託B時僅稱其房屋為海砂屋，並指示B在房屋現況說明書上，就「建築改良物是否現有或曾有鋼筋外露水泥塊剝落之情事」、「其他重要事項(針對屋況、產權、使用權等有任何補充)」等選項均勾選「否」，並於被害人X1、X2、X3欲合資購買本件房地時，面對X1有關房屋狀況之詢問，A僅透過B告知2樓房屋

35 參照：智慧財產法院105年度刑智上易字第38號刑事判決。

曾經發生氣爆之事，惟仍刻意隱瞞本案房屋臥室樓板曾有鋼筋嚴重鏽蝕，部分已鏽斷，混凝土塊狀剝落及經新北市政府工務局發函要求立即停止使用陽台並進行修復補強等情事，致X1、X2、X3陷於錯誤，在要求將房屋價值由A所開之新臺幣8百20萬元降為7百70萬元，並得A同意後，購買本案房地，X1等3人並推由X2以X3名義與A簽立不動產買賣契約書，並如數支付價金³⁶。

對此事實關係，法院除就上述交易上重要之事項之隱瞞，認為是A所施之詐術，使X1、X2、X3陷於錯誤外，對於A之辯護人所提出，本件房地之價格，已經由原本A開價之新臺幣8百20萬元降至新臺幣7百70萬元之主張，本件法院則認為，由於本件房屋不僅具有上述缺陷狀態，新北市政府工務局也已函知停止使用陽台，而本件房屋之「臥室側陽台外推，則原有側陽臺之樓板已成為本案房屋室內之一部分，該陽台既經禁止使用，對告訴人及被害人等而言，已難確保其等購買本案房屋原有使用目的之實現，是在告訴人及被害人等支付價金之時，……該等財產之惡化狀態更已現實導致告訴人及被害人等就本案房屋原有使用目的之無法成就，應屬告訴人及被害人等之整體財產損害」（粗體字為筆者所強調）³⁷。因此，法院肯定被害人受有財產損害及詐欺罪的成立³⁸。

³⁶ 此處之事實關係是摘要自臺灣高等法院104年度上訴字第2584號刑事判決。

³⁷ 參照：臺灣高等法院104年度上訴字第2584號刑事判決。除本件與上述【事例7】的判決外，同樣採取「整體財產」概念，並比較被害人為處分行為前後的資產金額變化的判決，例如：臺灣高等法院95年度上訴字第30號刑事判決、臺灣高等法院98年度上訴重更(一)字第39號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院99年度上訴字第1640號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院100年度上訴字第194號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院100年度上訴字第382號刑事判決、臺灣高等法院101年度上訴重更(一)字第211號刑事判決、臺灣高等法院102年度上訴字第1388號刑事判決等參照。

³⁸ 關於本件判決的解讀與對於本文主題的意義，匿名審查人之一指出：此判決是否有可能解讀為法院實際上是重視被害人購買房屋後財產狀態惡化，而並非將交易目的當作是重點？對此，筆者的說明如下：
筆者引用本件判決的理由在於，本件判決明確地提到被害人因被告隱瞞重要的資訊而購買了部分面積無法使用之房屋，導致整體財產受損，並以此作為詐欺

三、分析與檢討

(一) 被害人因詐術所生錯誤之內容對詐欺罪成否的影響

透過本文上述(貳、一、)的考察，可觀察得知我國詐欺罪刑事事實務中，有關被害人因錯誤而為處分的部分，實務傾向大致如下：

第一，詐欺罪的成立上，基本上實務均將被害人基於錯誤而同意交付財物時，其錯誤的內容為何的問題納入考慮。這點從上述【事例1】【事例2】【事例3】【事例4】【事例5】【事例6】【事例7】【事例8】【事例9】【事例10】【事例11】的法院判決中，法院判決中考慮到被筆者編列為①之要素可知。亦即，【事例1】的判決中的①

罪成立的理由。本件中，法院確實提到可以認定整體財產受損的原因，是因為被害人以使用房屋為目的，購買本件的交易標的即房屋，但實際上卻買到一部分經政府通知因安全問題無法使用的房屋，此處已經產生了對於被害人財產的具體危險。不過必須釐清的是，本件事實關係上較為特殊之處在於，被害人一開始購買的房屋並非正常的房屋，而是已經有相當嚴重的鋼筋鏽蝕及混凝土塊剝落等狀態的海砂屋，同時在法院的事實認定中，被害人已經透過證人知悉本件房屋有上述缺陷（本件判決理由壹、二、(一)，以及壹、二、(三)3部分參照）。因此本件並非被害人要購買正常、安全的房屋使用的通常情況，而是被害人已經知道房屋是海砂屋的情況下，仍有加以使用的目的（本件判決並未認定被害人的使用目的的具體內容為何），並進而購買該房屋。既然房屋本身有瑕疵並非問題（因為被害人仍決定購買），則對於被害人是否受到損害而言重要的關鍵自然會是被害人原本購買房屋要使用的交易之目的是否達成。而這個交易目的客觀上當然也會影響房屋本身的價值。

其次，從詐欺罪理論的觀點來看，交易目的倘若無法達成，那麼被害人實際上是買到了一個客觀價值低於其所支付價金所欲取得的房屋。在採取個別的財產概念時，由於其支付買賣價金給出賣人即被告，是因為這種影響房屋價值的事項發生錯誤，則應認為其交付買賣價金本身就是財產損害。另一方面，採取整體財產說的觀點，因為交易時要實現的使用房屋之目的無法在本件房屋中實現，所以可以認為行為人的整體資產在購買房屋後是較購買房屋前減少，在此意義下也可以認為被告受有財產損害。倘若如此，則法院是在可以使用個別財產說的觀點肯定本件財產損害的解釋途徑存在時，使用了整體財產說的論述。筆者引用此一判決，是要藉此顯示事實上法院在詐欺罪的財產損害的問題上，也還不算是有穩定的趨勢或立場。也因此，本文才會將提供法院解釋的可能性作為探討的主要問題意識。

要素顯示被害人的錯誤發生於其所投資基金的投資標的；【事例2】的判決中的①要素顯示被害人的錯誤發生於投資之塔位可否買回；【事例3】的判決中的①要素顯示被害人的錯誤可能發生於被告是否為知名企業少東的身分、【事例4】的判決中的①要素顯示被害人的錯誤發生於建築物本身結構是否安全；【事例5】的判決中的①要素顯示被害人的錯誤發生於建築物內是否曾發生自殺或凶案；【事例6】的判決中的①要素顯示被害人的錯誤發生於添加物是否合乎有關食品安全之法令；【事例7】的判決中的①要素顯示被害人的錯誤發生於使用於浸泡蔬菜之化學物質是否合乎有關食品安全之法令；【事例8】的判決中的①要素顯示被害人的錯誤發生於被告是否具有律師資格；【事例9】的判決中的①要素顯示被害人的錯誤發生於被告是否具有議員身分而其雙重國籍將影響議員身分被解職；【事例10】的判決中的①要素顯示被害人的錯誤發生於被告之結婚意願；【事例11】的判決中的①要素顯示被害人的錯誤發生於被告收受捐款後是否用於慈善用途。

第二，從上述各案例中，法院是否認為被告行為成立詐欺罪的結論可知，引起被害人的錯誤之內容為何的問題，有可能會導致詐欺罪成立（上述【事例1】【事例4】【事例5】【事例6】【事例8】【事例10】【事例11】的判決），但是也可能導致詐欺罪不成立（上述【事例2】【事例3】【事例7】【事例9】的判決）。

第三，值得注意的是，這些導致詐欺罪成立或不成立的錯誤內容，是否均與詐欺罪的保護法益即財產法益有關？

從法院認為詐欺罪不成立的判決來看，【事例2】的判決中法院認為被害人締約時並無發生對其財產的錯誤；【事例3】的判決中法院認定了被害人X3本身另外可從被告A在賭場的賭博行為取得利益，並未將被告的身分作為成立詐欺罪的根據之一；【事例7】的判決中被告在法令上並無告知義務，從而沒有施行詐術；【事例9】的

判決中法院著重的是形式上被告於領取各種費用時仍有民意代表的身分，並無施行詐術。在此意義下，法院不僅重視被害人的各個財產處分當時，事實上有無發生錯誤，並且看似較為嚴格地認為被害人對財產法益的處分本身發生錯誤時，才肯定其錯誤下所為的處分法益行為可作為詐欺罪成立的基礎，除此之外應認為詐欺罪不成立。

然而，與此相對，若從上述第一點的各判決中被害人發生錯誤的內容來看，可知在我國實務上，不論是有對待給付的情形，或者是無對待給付而片面地提供財物的情形，法院在判斷被害人同意處分財物時的錯誤是否是詐欺罪成立所必要的錯誤時，儘管也有考慮與被處分之財物或提供之勞務的價值、數量、品質有關的要素（例如上述【事例1】【事例4】【事例5】的判決），但是也可能考慮無直接關連的要素。最為明顯的例子，即是在上述【事例10】的判決中的被告結婚意願、【事例11】的判決中的慈善用途。這兩個判決分別意味著，結婚與否等人際關係上的考慮（上述【事例10】的判決），以及處分行為的社會意義（上述【事例11】的判決），均有可能納入適合作為詐欺罪構成上被害人之錯誤的內容中。更值得注意的是，【事例6】的判決中法院更考慮了刑法以外的其他法領域亦即食品安全衛生管理法的立法者意思。

第四，以上述第一至第三點為前提，應更進一步思考的根本問題是，為何我國的實務在詐欺罪被害人錯誤的問題上，會考慮這些與法益無直接關係的要素？

關於此一問題，應可從上述【事例6】的判決窺知法院的立場。亦即，上述【事例6】的判決中，法院在認定事實時，詢問本件各被害人，確認了被害人倘若知悉被告所使用的石膏並非政府公告許可使用的石膏時，就不會向被告購買石膏的意思。在這種判斷的構造中，只要被害人的錯誤與其決定處分財產交付財物之間有條

件關係，即肯定詐欺罪的成立。

（二）兩種不同財產損害概念對詐欺罪成否的影響

有關於詐欺罪的財產損害的我國實務現況中，可見到兩種不同立場，已如上述。問題在於，這樣的兩種立場，究竟對於詐欺罪的成立上有何影響？關於此一問題，至少有以下幾點值得注意：

第一，上述的整體財產概念下，倘若貫徹經濟上的觀點，由於必須要考慮被害人所交付的財物與所得到的對待給付是否相當的問題³⁹，其所包含的財產損害範圍將較狹（例如上述【事例7】的判決）。

第二，上述個別財產說的見解是將個別財物的交付認為即是詐欺罪的財產損害本身。這樣的財產損害概念下，即使被害人所交付的財物與所得到的對待給付相當，仍然可以成立詐欺罪（例如上述【事例12】的判決）。應該可以掌握到最廣的損害內容⁴⁰。

第三，從詐欺罪成立的理論觀點來看，因為被害人因財產處分受有損害必須與先行的詐術行為有因果關係，所以在此必須更進一步探討的問題是，我國實務中存在的這兩種財產概念與被害人同意交付、處分財產時的錯誤內容之關係為何？

首先，倘若貫徹個別的財產概念，因為其將被交付的財物本身認為是財產損害之所在，所以倘若貫徹這種財產概念，理論上不論被害人的交易目的內容為何，只要與財物持有或所有的移轉與被害人的處分行為有因果關係，即能肯定被害人受有財產損害與詐欺罪

³⁹ 參照：井田良，詐欺罪における財産の損害について，法曹時報，66卷11号，頁2995（2014年）。

⁴⁰ 學理上甚至也有認為，採取這樣的詐欺罪財產損害概念，幾乎等於實質上在詐欺罪中放棄財產損害的要素。參照：西田典之著、橋爪隆補訂，刑法各論，7版，頁220（2018年）。

的成立。

其次，倘若貫徹整體財產概念，理論上這種財產損害的認定中，考慮的重點是對待給付與行為人所交付的財物價值是否相當的問題，並且以資產的變化本身作為判斷標準。從而，倘若要一貫地運用整體財產概念，則在透過比較被害人交付財物前、後的總資產狀態後可認定其並無減少時，理論上不論被害人的交易目的內容為何，即應認為被害人並未受到財產損害，同時否定詐欺罪之既遂。

第四，值得注意的是，儘管採取整體財產說，有可能發揮較為限縮詐欺罪處罰範圍的功能，但是在上述【事例13】的判決中，亦可見到法院在認定被害人受有整體財產損害的同時，也指出被害人主觀面要達成的交易目的（對於房屋的使用）並未達成。倘若以上述第三點的觀察為基礎，在詐欺罪成否的判斷上採取整體財產概念時，為何需要指出或考慮這種存在於被害人主觀面的交易目的？即成為問題。

第五，上述兩種不同的財產概念均可見於我國詐欺罪實務的事實，意味著這兩種立場在以下的意義上，均可能採為我國刑法典中詐欺罪的解釋論。

首先，儘管詐欺罪的條文上並無如同背信罪一般規定財產損害的文字，但是考慮到詐欺罪既然作為財產犯罪，以保護財產為其內涵，因此要求詐欺罪的被害人需受有財產損害，並且考慮到經濟交易是詐欺罪的核心之一等要素，因此從經濟觀點理解詐欺罪的財產損害⁴¹，則在理論上，即有可能與此同時將詐欺罪理解為保護整體財產的犯罪⁴²。並且，以此為前提，採取整體財產概念，並採取比

41 參照：林幹人，刑法各論，2版，頁144（2007年）。

42 參照：蔡聖偉，概說：所有權犯罪與侵害整體財產之犯罪（下），月旦法學教室，70期，頁50（2008年）。

較交付財物前、後的被害人財產資產狀態變化，即所謂的「結算原則」作為財產損害的認定方法。

其次，與此相對，解釋論上同樣也有可能考慮我國詐欺罪的條文中並無財產損害的明文，而認為財產損害的要素並無條文上根據，從而認為應該採取個別的財產概念⁴³。

（三）詐欺罪擴張處罰之危險所在與本文進一步的課題

1. 關於詐欺罪擴張處罰危險的分析與檢討

以前述內容中對於我國詐欺罪實務的分析為前提⁴⁴，在此將進一步透過以下各點的檢討，掌握詐欺罪實務中所隱含的擴張處罰之危險所在。

第一，是有關於被害人因詐術所生之錯誤的內容納入財產以外事項的問題。從前述貳、三、（一）的我國詐欺罪實務之分析可知，實務在詐欺罪成否的判斷上，即使是對財產以外的事項發生錯誤，仍有可能加以考慮並作為認定成立詐欺罪的根據。這樣的判斷，事實上是完全以被害人為基準，將被害人在考慮是否處分或交付財物基礎的各種事項均納入判斷中。倘若這是實務判決中隱含的立場，則這應該是造成詐欺罪之在處罰範圍上容易擴張的重要原因之一。其理由在於，如此一來，即有可能透過將與保護法益（被害人財產）不直接相關的要素納入被害人所生的錯誤內容，因此將導致詐欺罪被害人處分法益的同意更容易無效，從而擴大詐欺罪的處罰範圍，使詐欺罪的保護範圍擴張至其他行政等法律（例如食品安全衛生管理法等）的遵守，甚至擴張用於保障人際交往關係的真摯（例如是否真有結婚或戀愛交往之意思等）。

43 參照：陳子平（註1），頁567。學理上相同旨趣的主張，可參照：山口厚，新判例から見た刑法，3版，頁278（2015年）。

44 參照本文貳、三、（一）與（二）之內容。

更進一步的問題是，倘若食品安全衛生管理法等刑法以外的行政法律的保護目的都能成為詐欺罪成立判斷的要素或基礎，那麼一旦貫徹這種觀點，則即使是現在被實務否定者，例如上述【事例9】的判決中的被告之國籍要素，也無將其排除於詐欺罪被害人錯誤之內容的必然性⁴⁵。

第二，既然整體財產概念與個別的財產概念，在解釋上均有可能作為我國實務在判斷詐欺罪成否時採取的選項，則貫徹個別的財產概念當然也有可能成為我國詐欺罪實務的解釋論立場。而如前所述，這樣的立場有促進擴張處罰的功能。另一方面，整體財產概念即使可能發揮較為限定處罰範圍的功能，但是如同前述【事例13】的判決所暗示的，倘若——姑且先不問理論根據是否充分的問題——採取這種財產概念之同時也可能考慮被害人進行交易的目的，並且——如本文後述內容中所舉的學說見解所示——更進一步認為交易目的有可能在整體財產概念中發揮擴張詐欺罪處罰範圍功能時，那麼，一旦毫無限定地將前階段的被害人錯誤中所涉及的交易目的均納入考慮，則整體財產概念究竟還能發揮如何的限定處罰功能，也可能成為問題。

第三，因為被害人的錯誤之內容，以及被害人的財產損害在詐欺罪的結構中均處於連貫的因果關係上，所以儘管我國學說一般尚未充分地有所意識，但是理論上，應可將上述分別在兩個領域中可見的不同立場，進一步加以對應後，得到以下的組合關係，並藉此較為明確地掌握上述各種考慮立場或要素下可能對詐欺罪處罰範圍造成的影響。

45 如同學說指出的，倘若能認為國籍象徵公職人員對於國家的效忠，則也可能認為當行為人就自己具有之有效外國籍加以隱瞞，並宣誓就職擔任我國民意代表時，負責處理其宣示相關事務的國家公務員就此發生錯誤，支付其薪資及其他費用的國家則發生財產損害。關於此點，可參照：薛智仁（註20），頁207-210。

亦即，從上述的說明可知，我國詐欺罪實務中，關於詐欺罪被害人錯誤之內容，固然有（a）傾向較為嚴格地從與財產的關連性加以考慮者（上述【事例1】【事例4】【事例5】的判決），也可見到（b）傾向較為廣泛地從被害人是否在得知事實後就不會交付財物的觀點，將被害人想要達到的各種目的均納入考慮者（上述【事例6】【事例10】【事例11】的判決）。另一方面，在詐欺罪財產損害的概念中，也可看到我國詐欺罪實務中，固然有採取（甲）個別財產概念，以個別財物交付本身作為財產損害者（上述【事例1】【事例12】的判決），與採取（乙）整體財產概念，以被害人的整體財產狀態惡化，或併用整體財產狀態惡化、被害人交易目的無法達成作為財產損害者（上述【事例7】【事例13】的判決）。

倘若就被害人的錯誤內容採取（a）之立場，則因為一開始在能肯定錯誤的範圍上就較為限縮，從而不論於財產損害的概念中採取（甲）或（乙）的概念，處罰範圍均較為限定。

倘若就被害人的錯誤內容採取（b）之立場，則在被害人的財產損害領域採取（乙）概念時（（b）+（乙）），在學說上也承認可能考慮被害人的交易目的等要素的限度內，詐欺罪的成立範圍同樣有可能擴張。因為被害人的交易目的可能僅存在於其主觀面的喜好等原因。

倘若就被害人的錯誤內容採取（b）之立場，則當在被害人的財產損害領域採取（甲）概念時（（b）+（甲）），詐欺罪的成立範圍幾乎可以涵蓋任何只要被害人知道事實就不會作成的個別財產交付，倘若如此，如前所述，各種政策上、人際關係上，以及被害人主觀喜好上的要素都將被詐欺罪所涵蓋入保護範圍，導致形成相當廣泛的處罰範圍。而在這種情況下，相較於採取（乙）概念的情形，因為在交易價值相等時，也可能肯定詐欺罪之成立，所以將會得到最大範圍的處罰擴張，詐欺罪領域也將發生毫無限定的危

險⁴⁶。如此一來，這樣的處罰範圍之擴張將造成詐欺罪「脫財產犯化」的危險⁴⁷。

2. 本文進一步的課題

歸納上述的各點後，即可知：一方面，儘管詐欺罪作為財產犯罪，以財產損害作為其法益的內涵是相當自然的道理，但是在財產損害概念的選擇上，個別的財產概念雖然較為符合文義，但是可能導致詐欺罪處罰範圍的擴大；整體財產概念雖然可能導出較為限定的詐欺罪處罰範圍，但是在我國刑法的文義上欠缺根據，並且也可能因為考慮被害人的交易目的等因素讓其限定處罰的功能有所折扣。

另一方面，在被害人因詐術所生的錯誤的領域，被害人的錯誤內容倘若納入非財產的目的或要素，將可能使詐欺罪保護範圍超越財產保護，進一步將人際關係或國家的行政目的也納入保護範圍內。

同時，上述的兩個概念中，詐欺罪的財產損害雖然屬於保護法益的內涵，被害人因詐術所生的錯誤則另外屬於構成要件行為即詐術行為所生的結果，兩者看似屬於不同領域，但是如同本文前述內容所示⁴⁸，兩個概念透過詐欺罪結構上要求的因果關係的串連，可能發生相互影響。

如此一來，為了對應上述詐欺罪處罰擴張的危險，本文必須進一步對以下的問題進行探討。

46 參照：佐伯仁志，詐欺罪（1），法學教室，372号，頁108（2011年）。

47 參照：葛原力三，財產的損害のない詐欺罪，收於：井田良等編，山中敬一先生古稀祝賀論文集（下卷），頁207（2017年）。同旨趣的主張，可參照：薛智仁（註20），頁224；許恒達（註20），頁25-26。

48 參照本文貳、三、（三）1.之內容。

第一，需要在詐欺罪的保護法益即財產概念上進行釐清。具體而言，首先須在掌握學理上可能的財產概念後，探討在整體財產的概念中，是否還需要考慮被害人的交易目的？如果需要，應考慮至如何程度？另外，採取個別的財產概念後，是否即毫無限定的可能性？倘若有，則應如何調整或修正個別財產概念的理解？這是本文以下將進行探討的第一個課題。

第二，需要在被害人錯誤的內容上進行釐清。具體而言，倘若被害人的錯誤之內容中，與財產無關者的考慮將導致詐欺罪的處罰過度擴張至脫財產犯化，那麼在解釋上盡量地不將其納入即是應設定的目標。而如何提供其理論的基礎，即是本文以下將進行探討的第二個課題。

關於此一課題的探討，考慮到詐欺罪的構造，是一種被害人基於自己處分自己財產法益的意思（透過將財物交付他人）而受侵害的構造。而這樣的構造也與刑法總論的被害人同意領域中的行為，亦即被害人基於同意而處分自己法益並受侵害的構造相同。基於這樣的構造上類似性，將被害人同意的理論領域中，對於被害人因錯誤所做成之同意是否有效的理論，進一步運用在詐欺罪的解釋論，應有其可能性。從而對於被害人同意領域的理論狀況的掌握，以及可運用於限定詐欺罪解釋的可能理論之探討，也將成文本文探討第二個課題時的重點所在。

第三，如上所述，詐欺罪的構造中，財產損害的概念與被害人因詐術所生錯誤的內容既然可能加以組合，則也有必要進一步檢討，若根據上述第一與第二課題的探討所得，應如何理解詐欺罪的構造的問題。本文也將此作為以下將進行探討的第三個課題。

參、詐欺罪處罰擴張的限定解釋可能性之探求

在以下內容中，本文將就上述對於我國實務現況的檢討分析所得的三個課題，繼續進行探討。考慮到（1）本文的主要目的是希望透過目前已經有的學理提供實務可能的解釋論方向；（2）我國的刑法學界，不論是關於詐欺罪的財產損害的領域，以及詐欺罪的詐術乃至被害人同意的領域，基本上已有相當程度的累積，因此本文以下內容中，針對詐欺罪財產損害概念的問題，以及被害人的錯誤之內容的問題，將先掌握向來的我國學理狀況，再進一步地透過檢討，探求可能的解釋方向。並在此基礎上嘗試以本文的觀點理解詐欺罪的構造。

一、詐欺罪之財產損害概念的再思考

（一）有關詐欺罪之財產損害應如何掌握的我國學說現況

關於詐欺罪的財產損害應如何掌握，我國學說有以下幾種不同的見解。

第一，是我國的通說，採取所謂的整體財產說，在將詐欺罪理解為一種保護整體財產（被害人的總資產）的犯罪的前提下⁴⁹，採取所謂的「結算原理」，以處分行為為分界，比較其前後的被害人資產狀態，並在可認為被害人資產因處分行為而減少時，肯定被害人受有財產損害⁵⁰。

49 例如：蔡聖偉（註42），頁50-51；薛智仁（註20），頁204；許澤天（註1），頁105等參照。

50 參照：黃榮堅，刑法解題——關於詐欺等財產犯罪，輔仁法學，9期，頁106（1990年）。關於結算原理的簡要說明，另可參照：許恒達，偽裝化緣與捐贈詐欺——評板橋地院88年度易字第4578號判決，台灣法學雜誌，218期，頁136-137（2013年）；許澤天（註1），頁136。以同樣方式判斷財產損害者，也可參照：蔡聖偉（註42），頁51。最近也有研究透過對於德國刑法實務與學說的詳細考察，將詐欺罪的財產損害理解為涵蓋被害人實際上的財產減少，以及被害人處分行為時所生對於財產之危險的概念，並且主張應該以破產會計作為損害

第二，我國的少數說的見解，則是採取所謂的個別財產說，將詐欺罪理解為保護個別財產的犯罪，認為被害人處分、交付的財物本身，就是損害之所在⁵¹。

上述兩說的立場差異，來自於其對於詐欺罪文義解釋的不同。亦即，少數說較為嚴格地解讀我國詐欺罪的基本條文即刑法第339條第1項之文義，認為相對於明文地將財產損害放入構成要件中的同法第342條第1項背信罪⁵²，因為刑法第339條第1項的條文並無「財產損害」的文字，所以將詐欺罪理解為是保護個別財產的犯罪，毋寧是條文上自然的理解⁵³。另一方面，我國通說則是認為詐欺罪既然是保護財產法益的財產犯罪，則其成立上以財產法益受侵害為要件是當然的要求，因此必須在物之交付以外更為實質地觀察有無財產上的損害⁵⁴，至於條文上並無規定，並非絕對的根據⁵⁵。

關於詐欺罪的具體成立範圍，在行為人與被害人之間存有對待給付，且行為人交付給被害人的物之客觀價值低於被害人給付的價額時，上述兩說的差異較不明顯。但是在（1）行為人與被害人各自所為的給付價值相當的情形，以及（2）被害人以片面贈與等方式單方面移轉其財物支配，而未取得對待給付的情形，即可見兩種解釋論上不同途徑導致的差異。

關於（1）的情形，例如【設例1】鐘錶商A將仿冒世界名牌甲

計算之輔助工具，以此明確化結算原則的判斷構造的見解。參照：惲純良，詐欺罪中財產損害之判斷——「財產危險」概念的回顧與展望，臺北大學法學論叢，103期，頁159-166、168-181（2017年）。

51 參照：甘添貴（註1），頁327；陳子平（註1），頁567-568。

52 其條文規定為：為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

53 同旨的主張，參照：陳子平（註1），頁567。

54 參照：蔡聖偉（註42），頁51；惲純良（註50），頁162-163。

55 參照：惲純良（註50），頁162。

牌的名錶一只，以結束營業換現金賤賣之理由，以新臺幣1萬元的價格賣給客戶X，X信以為真，買下該錶，但事後發現，雖然錶本身的價值有新臺幣1萬元，但是X實際上想買的是價值新臺幣50萬元的甲牌名錶，並非贗品⁵⁶。

關於（2）的情形，例如【設例2】A假冒和尚，披上袈裟並戴上偽造的宗教證件站在街頭，謊稱是為了建廟而化緣，往來行人中，X、Y、Z信以為真，各自投入現金新臺幣1百元，而A取得該等金錢後，即將其用於飲食，花用殆盡⁵⁷。

關於上述的（1）的【設例1】，對於我國少數說而言，因為X交付之買賣價金本身就是損害，所以詐欺罪的成立較無問題。但是，對於採取結算原理的我國通說而言，因為嚴格來說，被害人X所取得的手錶與其客觀價值相當，所以X在處分其買賣價金之前、後，其財產狀態並沒有減損，因此，在詐欺罪成否的問題上，顯然還需要提出其他根據，始能肯定財產損害。我國通說在此所提出者，即是被害人從事交易之目的。亦即，在將X是以買名錶為目的一事納入考慮後，即使買到的是價格相當的贗品，對X而言也是毫無用處，無法達成其目的，因此可認為X受有財產損害⁵⁸。

關於上述（2）的【設例2】，對於我國少數說而言，同樣可以認為被交付的財物本身即是損害，所以詐欺罪的成立也較無問題。但是，對於採取結算原理的我國通說而言，因為被害人從事的處分行為既然是贈與，則其處分在性質上必然包含自己財產的減損，所以當被害人就自己將要捐款一事本身有清楚的認識時，若在這種情況也要貫徹結算原理，那麼這種被害人已經清楚認識到的財

56 此例是參考林東茂（註31），頁208之例修改而成。

57 此例是參考許恒達（註50），頁132之例修改而成。

58 參照：林東茂（註31），頁205-206。同旨的見解，參照：許澤天（註1），頁145-146。

產減少，是否還能認為是被害人的財產損害，同樣在理論上也有疑問⁵⁹。此時在詐欺罪成否的問題上，對通說而言，同樣地還需考慮此一捐款背後的目的不能達成，始能認為X等人仍受有財產損害，並進而肯定詐欺罪的成立⁶⁰。

（二）作為詐欺罪解釋出發點之財產概念

從前述有關我國詐欺罪實務的檢討可知，個別的財產概念雖符合詐欺罪規定之文義，倘若貫徹則可能導致詐欺罪的保護法益過度膨脹至其他與財產無關的範圍。從處罰範圍限定的觀點，理論上整體財產說看似較為適合。但是，基於以下的理由，筆者認為關於詐欺罪的財產損害，也未必須採取整體財產說：

第一，倘若認為條文的文義是解釋論的重要前提，那麼個別的財產概念會是較為理想的出發點。

第二，如前所述，我國通說所主張的整體財產說之構造上，對於交易價值不相當的情況，是透過結算原則肯定詐欺罪的財產損害，但是對於交易價值相當的狀況，或者單方贈與的情況，則是透過被害人主觀的交易目的之考慮肯定詐欺罪的財產損害。為何對於同樣的行為客體即財物，整體財產說會使用不同的判斷標準認定有無財產損害，在理論上並非自明。與此相對，個別的財產概念在可以同時使用在有對價的交易行為，以及無對價的單方贈與等行為這點，可認為有其長處。

第三，即使考慮被害人主觀的交易目的，倘若該目的最終還是必須附麗於被交付的具體財物，則即使採取個別財產說，也能考慮整體財產說之中被考慮的要素。

59 參照：許恒達（註50），頁136；許澤天（註1），頁146-147。

60 學理上有將此稱為「目的欠缺理論」，參照：許恒達（註50），頁137。關於此一理論，另亦可參照：許澤天（註1），頁147。

第四，在具體的適用上，我國通說，同時併用處分行為後被害人財產的經濟狀態比較，以及被害人的交易目的是否能達成的標準的途徑。雖然考慮到交易目的後，確實可能掌握以經濟「交易」為核心內涵的詐欺罪，但是，一方面，倘若僅考慮被害人進行交易的主觀目的，則如前所述詐欺罪的成立範圍將過度地擴張，甚至可能在未成年的17歲青少年偽裝成年人而支付價金購買酒類的情形，也認為成立詐欺罪，顯然不妥當⁶¹。但是，倘若還需要更進一步限縮，則應該採取如何的途徑，仍然是個難題。另一方面，就本文前述我國詐欺罪實務中可見，一般也認為是典型應成立詐欺罪態樣的慈善捐款詐欺這種由被害人單方面給付的情形，應如何考慮其主觀「目的」，同樣成為解釋上的難題⁶²。因為，這種作為慈善捐款的單方給付，通常具有的是救濟貧困這種無法換算為金錢的社會上意義，而與被害人支付的「財物」，難以認為有對應交換的適合性⁶³。

基於以上的理由，筆者認為在詐欺罪財產損害的解釋上，應該以個別的財產概念為出發點。當然，接下來成為問題的即是應如何才能夠在符合法條文義的同時，在處罰範圍上也較為限定？對於此問題，筆者認為，可以透過以下的方式對個別的財產概念進行修正：

首先，詐欺罪的被害人受到的財產損害，是其作為法益主體處分其法益即財產，將財物的持有支配移轉於行為人的結果。財產法益的處分既然是法益主體對於其法益的處分，則考慮法益主體就該處分所設定的主觀目的，理論上即有理由⁶⁴。本文之前對於我國實

61 參照：佐伯仁志，詐欺罪の理論的構造，收於：山口厚等編，理論刑法学の最前線II，頁106（2006年）。

62 參照：許恒達（註50），頁138。

63 參照：佐伯仁志（註3），頁114；許恒達（註50），頁138。

64 參照：佐伯仁志（註61），頁107。同旨趣的主張，另可參照：許恒達（註50），頁136。

務的分析所示，單純採取個別的財產概念，且除此之外無任何限定，即可能導致詐欺罪的處罰範圍擴張。因此，若以個別的財產概念為出發點，要避免此一解釋上的問題，在財產損害的概念內容中，除了個別財物的交付以外，也應考慮「被害人處分財產之目的」。

其次，從本文對於我國實務的考察也可知，「被害人處分財產之目的」中，含有與財產法益無關的考慮，並且將這種考慮納入詐欺罪的成立要件時，顯然無法達成限縮詐欺罪處罰範圍的目標。在此意義下，「被害人處分財產之目的」的考慮，即應將其限於有經濟上意義的部分，才能與詐欺罪作為財產犯罪的性質相符合，並且對於處罰範圍的限定始能有所裨益。問題在於這種經濟上的意義應如何界定？

關於此一問題，學理上至少還存在兩種可能的思考方式：

第一，考慮交易雙方在交易過程中達成的共識，或者透過長期的交易習慣默示地形成的共識，作為財產處分者的「目的」⁶⁵。不在這些共識範圍內者，則排除於詐欺罪成立的考慮之外。

第二，同樣從經濟的觀點出發，但是不認為被害人的主觀交易目的有決定性的重要性，而是著眼於【A】客觀上，【B】從被害人所為的個別的財產給付，【C】是否能體現其對被害人有經濟上重要的目的來觀察⁶⁶。此一見解在我國被稱為「功能的財產概念」⁶⁷。從著眼於被害人的個別財產給付的觀點來看（上述【B】），這種見

65 參照：足立友子，詐欺罪における「欺罔」と「財産的損害」をめぐる考察——損害概念の多義性と中間結果としての錯誤に着目して——，收於：川端博等編，理論刑法学の探究6，頁153（2013年）。

66 此一見解已見於日本刑法學界。參照：佐伯仁志（註3），頁109；佐伯仁志（註46），頁108。我國刑法學界同旨趣的主張，可參照：許恒達（註50），頁139-141。

67 參照：許恒達（註50），頁139。

解本質上應仍是一種個別的財產損害說，另外，從考慮財產給付是否有經濟上重要的目的來看（上述【C】），此一見解在排除無經濟上意義的目的上，可以發揮限定詐欺罪處罰範圍的功能。

上述兩種見解中，第一種見解下的「目的」，除了沒有明確的判斷標準的問題，以及單方面給付財產的類型（例如偶然地在路上進行小額慈善捐款的情形）中並無這種共識可循的問題以外，即使採取這種見解，仍可能因為當事人雙方將無關財產上的事項納入共識中，而使得詐欺罪同樣地擴張處罰範圍而成為保障非財產的犯罪，並不妥當。

在此意義下，第二種見解應是在我國詐欺罪條文文義下，要妥當界定詐欺罪損害概念範圍時，較能採取的一種見解⁶⁸。然而，在此成為問題的是，在這樣的見解下，應如何對各類詐欺罪中的財產損害加以說明？關於此一問題，在此分就以下數點說明：

第一，當財產損害是因交易而生，則這樣的交易所得的對待給付之客觀經濟上價值若有重大的錯誤，自然符合上述【A】【B】【C】的要素，可以認為被害人發生財產上的損害。

第二，與此相對，儘管被害人將交易相對人的身分、國籍等要素（例如前述巧取公職的情形）設定為交易時的極重要考慮，但是只要這種要素無法認為在被害人所為的具體交易中，有經濟上意義，則即使無法與具有被害人所設定身分的相對人交易，也無法認為被害人受有損害⁶⁹。

⁶⁸ 在此可補充說明的是，如本文前述，這種功能的財產概念下，被害人處分法益之目的的考慮，因為需依附在個別財產的交付，所以實際上本文仍將其定位為一種個別的財產概念。但是與我國目前現有的個別財產說相比較，功能的財產概念將被害人處分法益時有無可以客觀化且於經濟上重要的目的納入財產損害概念中，將比向來的個別財產說增添篩選用的概念，因此功能的財產概念下的財產損害範圍較為限定。

⁶⁹ 可以附帶一提的是，在規範上雖然無法使用詐欺罪處罰，但是這種情形很有可

第三，當財產損害是因單方面的給付行為而生，則隨該給付行為為被交付的財物通常可以滿足上述【A】【B】的要素，但是【C】的要素是否具備則需依不同情形區別處理：

（1）例如在慈善捐款的情形，由於捐款的目的是要讓需要幫助者在經濟上得到援助，因此當這樣的目的無法達到時，自然可以認為在經濟上重要的目的無法達成⁷⁰。

（2）例如在慈善捐款的情形，募款者為能多募款項，向捐款者謊稱其鄰居多捐了很多，讓捐款者為了面子捐出更多金額的情形⁷¹，由於這種情況下被害人所交付的捐款實際上用於捐助，交付更多金額的目的並非經濟上的考慮，而是虛榮或面子等要素，從而應該要認為【C】的要素並不具備，被害人並無財產上損害。

（3）例如在戀愛或結婚詐欺的情形，倘若被害人提供資金，是以將來結婚後與行為人一同經營具體的事業或創業為目的，則此時應該認為【C】的要素具備，被害人受有財產上損害⁷²。

（4）同樣是戀愛或結婚詐欺的情形，倘若被害人提供資金，是單純因為對於結婚的期待，或者戀愛感情發展的期待而為，則此時應認為不僅【C】的要素不具備，上述【A】的要素也同樣不具備，從而無法認為被害人受有財產上損害。

在上述的具體應用中，可進一步就以下幾點加以補充說明：

首先，是上述【A】【B】【C】三個要素之間的關係。考慮到此

能在其他特別法領域成立犯罪，而同樣地受到刑事制裁，或至少因違反行政法上的處罰規定而受行政制裁。若考慮到不同領域刑事制裁本身，以及刑事制裁與行政制裁之間也有分工，則應認為不應也不需要過度地適用詐欺罪。

⁷⁰ 參照：許恆達（註50），頁141。另外可以補充說明的是，這種經濟上重要的目的，並不包含這種行為的社會意義（例如救濟貧困的大愛義舉等）。

⁷¹ 參照：佐伯仁志（註3），頁113；許恆達（註50），頁141。

⁷² 參照：佐伯仁志（註3），頁119。

說的重點在於維持將個別財產交付作為前提的架構下，透過客觀上可以觀察或理解的經濟目的，試圖妥當地控制處罰範圍，因此，判斷時，必須確認經濟上重要的目的（【C】要素）是否已經客觀地（【A】要素）呈現在具體的個別給付中（【B】要素）。倘若答案是否定，則應否定財產損害的存在，倘若答案為肯定，則應肯定財產損害的存在。

其次，【A】要素要求的客觀性，【B】要素的具體給付內容在一般情形下相對地較為容易確定，【C】要素即「經濟上是否有重要性」之目的應如何判斷，則還需要進一步地加以明確化。而關於此一問題，因為「經濟上重要」實際上涉及到「經濟性有無」，以及「重要性高低」兩個部分，所以筆者認為可區分成以下的幾種情況加以探討：

第一，有高度重要性，但沒有經濟性的情形。亦即，被害人自行主觀地設定對自己有高度重要性的處分財產目的，但此一目的不具有經濟性的情況。在這種情況中，即應認為不合乎「經濟上重要性」的標準。典型的情況即如同上述之單純以結婚或戀愛交往等人際關係作為目的而提供財物的情形。例如：X完全以戀愛交往為目的，提供A數萬元當「交際費」，但A完全沒有交往之意思，領取「交際費」之後就斷絕音訊。這種情況中，（I）X提供金錢，（II）X想換取即設定的處分財產目的是A與自己談戀愛交往。在（II）的處分財產目的部分僅涉及人與人交往與否時，即應認為即使這樣的目的對X有高度重要性，但因為沒有經濟性，仍無法認為是「經濟上重要」，從而應認為並非詐欺罪的財產損害。

第二，有經濟性，且可認為有重要性的情形。同樣屬於上述的提過，不僅以結婚或交往為目的，還同時兼具投資或經營事業等目的的情況即可肯定有經濟上重要性。例如前述的例子中，倘若A對X謊稱要結婚，還謊稱以聘金新臺幣1百萬元名義，作為將來投

資、經營事業的基金，但是A取款後即避不見面也未實際從事投資。那麼這樣的情況中，(I) X提供金錢，(II) 想換取即設定的財產處分目的是A與自己戀愛交往且投資或經營事業。因為經營事業的部分可認為是經濟上重要的目的，所以這種情況仍可肯定有詐欺罪的財產上損害。

第三，有經濟性，但不具備重要性的情形。例如商店老闆A告訴顧客X，X要買的商品在A店內的價格已經是不能再便宜的跳樓價，X因此以比附近最低價略高的價格買下A店內的商品。在此例中，(I) X提供的是金錢，(II) X想換取即設定的處分財產目的是「盡量以較低價買某產品」。在(II)的處分財產目的部分，雖然購買商品本身有經濟上的性質，但是一般零售商業行為中行情本有彈性，不能因為各個店家所賣商品稍有價差就立即認為其價格不相當。因此，上述情形中即應認為這種盡量以低價購買的目的僅管有經濟上意義，但並不能認為重要，從而也非財產上損害。否則，一旦定價高於其他店家販售商品並強調自己便宜，即有可能成立詐欺罪，顯然是不妥當的過度處罰。

二、詐欺罪被害人錯誤內容之限定可能性的探求

(一) 有關被害人因錯誤而同意處分法益問題的我國學說現況

1. 各種學說的主張

在我國刑法學界，有關被害人因錯誤而同意處分法益時，其同意的有效性應如何判斷的問題，主要有以下幾種見解。

第一說，是將被害人的同意、承諾理解為不同概念，亦即將同意理解為是一種構成要件要素，承諾則理解為是阻卻違法要素，並在此基礎上設定同意因強暴、脅迫或詐欺而有瑕疵時，其有效性的

判斷標準⁷³。本文在此先將這種見解稱為「二分說」。在這樣的區分下我國多數的學說見解進一步認為，這兩種概念主要在(1)阻卻構成要件該當性的同意僅需於行為時客觀存在即可，但是阻卻違法性的承諾則需被害人至少於行為時將其意思表示於外；(2)阻卻構成要件該當性的同意即使存在受脅迫或欺罔等瑕疵，也不影響其有效性，但是阻卻違法性的承諾則可能因受脅迫或欺罔等瑕疵，影響其有效性；(3)行為人於行為時不需認識阻卻構成要件該當性的同意存在，但是行為人於行為時則需認識阻卻違法的承諾才能阻卻違法⁷⁴。

第二種見解，從較為實質的觀點，主張倘若可認為被害人得知真實的事實即不會為同意，則可認為其受脅迫或欺罔所為處分法益

73 採取這種立場者，可參照：林山田，刑法通論（上冊），增訂10版，頁368-372（2008年）；張麗卿，刑法總則理論與運用，7版，頁229-232（2018年）；林鈺雄，新刑法總則，6版，頁283（2018年）；林書楷，刑法總則，修訂4版，頁170（2018年）。另外也有學說同樣以阻卻構成要件該當性或阻卻違法性的效果區分為基礎，更進一步地細分成（1）被害人之承諾絲毫不發生刑法上之任何效果、（2）承諾屬於刑罰減輕事由之構成要件要素、（3）以被害人承諾（或稱為「合意」）之不存在做為構成要件要素、（4）被害人之承諾屬於違法性阻卻事由等四種分類（參照：余振華，刑法違法性理論，2版，頁337-338（2010年）；陳子平，刑法總論，4版，頁297-298（2017年））。另外也有將被害人之承諾細分為（1）在犯罪構成要件上不具任何意義的承諾、（2）減輕刑罰之構成要件要素、（3）阻卻構成要件該當性、（4）變更客體之處罰規定、（5）阻卻行為違法性等五種不同類型者（參照：甘添貴，被害人之承諾與違法性，軍法專刊，26卷12期，頁9（1980年））。關於此一論點，另亦可參照：井上祐司，被害者の同意，收於：日本刑法学会編，刑法講座第2卷，頁160-166（1963年）；曾根威彦，「被害者の承諾」と犯罪論体系——被害者の承諾・その二——，早稻田法学，53卷1・2号，頁93-103（1978年）；宮野彬，被害者の同意，收於：中山研一等編，現代刑法講座第2卷・違法と責任，頁109-117（1979年）；川原広美，刑法における被害者の同意（2・完）——自律性原理の確認——，北大法学論集，31卷2号，頁780-782（1980年）；山中敬一，被害者の同意における意思の欠缺，関西大学法学論集，33卷3・4・5号，頁923-929（1983年）；佐藤陽子，被害者の承諾（1）：各論的考察による再構成，北大法学論集，58卷3号，頁1070-1075（2007年）；吉田敏雄，被害者の同意における意思瑕疵，收於：井田良等編，山中敬一先生古稀祝賀論文集（上卷），頁237-239（2017年）。

74 參照：張麗卿（註73），頁231；林鈺雄（註73），頁283-284。

的意思表示均無效⁷⁵。學界也有將此稱為「主觀真意說」者⁷⁶。

第三種見解，是最近除上述兩種見解外的有力說，亦即「法益關係錯誤說」。此說同樣從實質的觀點，從被害人發生錯誤的事項之性質，先區分其錯誤是（1）與被處分之法益有關連性的錯誤⁷⁷（以下簡稱法益關係錯誤⁷⁸），亦即與法益侵害的種類、方式、範圍或危險性有關的錯誤⁷⁹，或是（2）與被處分的法益無關連性但是屬於作成處分之動機的錯誤。倘若被害人的錯誤是（1）法益關係錯誤，則可認為被害人對於自己正在處分自己的法益一事並無認識，因此可認為其所為處分法益的意思表示無效；倘若被害人的錯誤僅是（2）動機錯誤，則其所為之處分法益的意思表示則為有效⁸⁰。

2. 各說在具體案例的判斷結論

目前在我國的刑法學界，這種實質的判斷，以及其與向來見解的異同，則主要呈現在有關以下幾個犯罪類型的討論中，以下分別舉例說明之。

第一，有關刑法第275條第1項的加功自殺罪。

【設例3】情侶A與X因交往受到雙方家人極大反對與壓力，乃

⁷⁵ 關於此種主張的介紹，可參照：余振華（註73），頁347。

⁷⁶ 同前註。

⁷⁷ 參照：吳耀宗，被害人受騙之承諾，月旦法學教室，126期，頁29（2013年）；王皇玉，強制手段與被害人受欺瞞的同意：以強制性交猥褻罪為中心，臺大法學論叢，42卷2期，頁418（2013年）。

⁷⁸ 此一用語，參照：許恒達，變質的友情：侵入住居與妨害性自主之個案檢討，月旦法學教室，166期，頁25（2016年）。另外也有將其稱為「與法益相關的錯誤」者（參照：蔡聖偉，論強制性交罪違反意願之方法，中研院法學期刊，18期，頁76（2016年））。

⁷⁹ 參照：王皇玉（註77），頁419；蔡聖偉（註78），頁76。另亦可參照：佐伯仁志（註3），頁51；山中敬一，刑法總論，3版，頁219-221（2015年）。

⁸⁰ 參照：吳耀宗（註77），頁29；王皇玉（註77），頁418-419、422；許恒達（註78），頁25。

約定一同以燒炭自殺之方式殉情。但是事實上A是利用X對自己用情深厚，願意追隨自己自殺，藉此擺脫X而另尋人生的開始，乃假意與X一同燒炭，而A事前已與友人B約定在適當時間至A與X所在之地點將A帶出，B也依約履行，最終僅有X死亡⁸¹。

倘若採取上述通說的見解，認為有瑕疵的承諾一律無效，或者採取行為人如知道真相即不為同意的見解，即應認為此處X因誤會A真心想與自己一同殉情，因此其自殺之意思表示為無效，從而A之行為應成立刑法第271條第1項殺人罪的間接正犯⁸²。與此相對，倘若採取上述法益關係錯誤說的見解，由於X就自己的死亡結果，以及死亡方式等均無誤會，其誤會是發生在A是否處分A的生命法益之點，因此應否定其錯誤與自己法益之間的關連性，同時認為此一錯誤是不影響X處分自己生命法益意思表示之有效性的動機錯誤，從而應認為A之行為應成立刑法第275條第1項的加功自殺罪⁸³。

第二，有關刑法第306條的侵入住居罪。

【設例4】A以殺人的意思至仇家X的家門前，因X不在家，乃由其配偶Y應門，因A稱其與X有約，Y乃讓A入室，但其後A即對Y進行強制性交或強制猥褻的行為⁸⁴。

倘若採取上述通說的見解，認為有瑕疵的承諾一律無效，或者採取行為人如知道真相即不為同意的見解，即應認為此處Y因誤會A與X有約而使A入內的意思表示為無效，從而A進入X與Y之住所

81 此例是參考許澤天，刑法各論（二）：人格法益篇，頁52（2017年）之例修改而成。

82 參照：褚劍鴻，刑法分則釋論（下冊），增訂4版，頁927（2006年）；林山田（註1），頁83。

83 參照：陳子平（註1），頁42；許澤天（註81），頁52。

84 此例是參考許恒達（註78），頁24之例修改而成。

的行為成立侵入住居罪⁸⁵。與此相對，倘若採取上述法益關係錯誤說，則因為Y就讓A進入家門一事並無誤認，其所誤認者只是A有與X相約，這種誤認屬於動機的錯誤，不影響同意的有效性⁸⁶。

第三，有關刑法第354條的毀損罪。

【設例5】A謊稱要與X交往，並以自己討厭香水為由，要X放棄使用香水才能與自己交往，X相信A所言，乃將自己的香水全部交給A，由A當面銷毀⁸⁷。

若採取上述的向來通說見解或主觀真意說，則此例之中應認為X所為的法益處分意思表示無效，A應成立毀損罪。與此相對，若採取法益關係錯誤說，則因為X就香水要被銷毀本身並無誤認，其所誤認的是A是否與自己交往的人際關係問題，與財產並無關係，所以應認為其同意A銷毀香水的意思表示有效，A不成立毀損罪⁸⁸。

第四，有關刑法第221條第1項的強制性交罪。

【設例6】按摩師A男為客人X女進行淋巴排毒服務，但是在進行過程中，一方面以刺激性慾的藥物塗抹於X女陰道，並且又以舌頭、手及性器進入X女陰道，在X女詢問時則稱是要使X女放鬆，X女乃誤認自己在進行排毒療程，並未反抗或要求停止⁸⁹。

在此例中，若依上述通說見解或主觀真意說，則應認為X繼續接受A對自己性器之各種行為的意思表示因受欺罔而無效。若採取法益關係錯誤說，則可認為X同意的是排毒療程的保健行為，並非

⁸⁵ 參照：甘添貴（註73），頁11-12。

⁸⁶ 參照：許恆達（註78），頁25。

⁸⁷ 此例是參考吳耀宗（註77），頁27之例修改而成。

⁸⁸ 參照：吳耀宗（註77），頁29。

⁸⁹ 此例是參考王皇玉（註77），頁422之例。

性交，因此其讓A繼續其行為的意思表示為無效⁹⁰。

【設例7】A男並無支付對價的意願，但是對從事特種營業的X女表示願意支付X所開出的價錢，與X從事性交易。X為賺取A宣稱要支付的金錢，乃與A性交，但是性交後A並未付款⁹¹。

在此例中，若貫徹上述的向來通說見解，則因為強制性交罪中的同意是阻卻構成要件該當性的同意，因此即使受欺罔仍應認為有效。若採主觀真意說，則應認為X在其對於性交後所能取得的對價給付發生錯誤，足使其與A性交的同意為無效⁹²。與此相對，倘若採取法益關係錯誤說，因為X對於與A從事性交行為並無錯誤，其錯誤發生在A是否願意處分A的（他人的）財產，所以此一錯誤與X的性自主法益並無關連，則在這樣的考慮下應認為X的處分仍為有效⁹³。

【設例8】A宣稱要與交往中的X女結婚，要X與自己性交，X因相信A所言，乃答應與A從事性交行為，但A於與X性交後即與其分手⁹⁴。

在此例中，若採取上述的向來通說見解，則因為強制性交罪中的同意是阻卻構成要件該當性的同意，因此即使受欺罔仍應認為有效。若採主觀真意說，倘若能認為X若知悉A並無結婚意願，即不會與A性交，則可認為X與A性交的表示為無效。若採取法益關係錯誤說，則因為X對於與A性交並無誤認，其所誤認者為A將來是否願與自己結婚，亦即誤認A是否就其身分加以變更（進入婚姻），所以可認為這樣的誤認與X的性自主法益並無關連，從而X的意思表

90 參照：王皇玉（註77），頁423。

91 此例是參考王皇玉（註77），頁422之例。

92 同此結論，參照：林大為，論詐術性交罪——兼論「宗教騙色」案件之認事用法問題，軍法專刊，59卷5期，頁108-137（2013年）。

93 採取此一立場者，參照：王皇玉（註77），頁422。

94 此例是參考王皇玉（註77），頁422之例修改而成。

示仍為有效⁹⁵。

（二）法益關係錯誤說於詐欺罪的運用可能性

1. 各說的判斷構造與對處罰範圍之影響

從上述各說在具體的犯罪類型與設例的運用中，可知採取不同的見解，在實際上的案例中可能得到不同的判斷結論。從理論的觀點，這樣的判斷結論的相異，代表著採取不同的見解，可能影響處罰範圍的廣狹。這樣的影響可以從以下各點觀察得知：

第一，當被害人的錯誤發生在法益本身時，除了二分說是依照對於被害人處分法益意思的定位是同意或承諾，而有不同的有效性判斷結論以外，不論是主觀真意說，或者法益關係錯誤說，基本上均會否定被害人同意的有效性。上述【設例6】即為一例。

第二，而真正地可觀察出處罰範圍有效性的廣狹不同者，應是上述【設例3】【設例4】【設例5】【設例7】【設例8】的情況。因為這些情況中，被害人發生錯誤的事實，並非法益的性質、種類、數量等事項，而是其他的事項。亦即，【設例3】的被害人誤會的並非自己的生命法益之處分，而是行為人是否處分行為人法益，【設例4】的被害人誤會的不是自己的住居權的行使，而是行為人與自己的配偶是否有約，【設例5】的被害人並非誤認自己的財產權行使，而是行為人是否要與自己交往，【設例7】的被害人並非誤認自己的性自主權的行使，而是誤認行為人是否要處分自己的財產支付費用，【設例8】的被害人並非誤認自己的自主權行使，而是誤認被害人是否要與自己結婚。

第三，問題在於，理論上，上述各說所採的判斷構造中，導致如此的處罰範圍差異的要素為何？

⁹⁵ 參照：王皇玉（註77），頁422。

首先，我國通說的二分說是較為形式地以同意或承諾的區別為前提，並一貫地適用。因此，上述【設例3】至【設例8】的具體運用中，此說之下被害人因錯誤處分法益時，其處分無效導致犯罪成立的範圍即是這種形式運用的結果。

其次，主觀真意說的主張內容僅有被害人發生錯誤與做成法益處分之間的條件關係，因此只要有這樣的條件關係，即可以否定被害人因錯誤處分法益之意思的有效性。也因為在被害人發生錯誤的事項上並無限制，所以主觀真意說在實際上運用的結果，可謂只要被害人發生錯誤而處分法益，不論其所生錯誤之事項為何，均可以認為其處分無效。上述【設例3】至【設例8】，若採主觀真意說將全部否定各例中被害人處分法益的有效性，即是此說構造的具體呈現⁹⁶。

再者，法益關係錯誤說主張的核心在於對被害人發生錯誤的事項有進一步的區分，因此相較於主觀真意說，法益關係錯誤說在構造上，不僅要求後階段即被害人發生錯誤後，其錯誤需與被害人對法益的處分有條件關係，同時也要求在前階段即被害人發生錯誤時，其錯誤之事項需與法益的內涵有關連。也因此，當被害人發生錯誤之事項與法益無關時，法益關係錯誤說仍會肯定被害人因此處分法益的有效性，從而上述【設例3】至【設例8】的具體運用中，若採法益關係錯誤說，除【設例6】以外，均會肯定被害人處分法益的有效性，即是此說構造的具體呈現。

第四，透過上述各點的分析可知，從可能認為被害人處分其法益的意思表示無效的範圍廣狹的觀點而言，所謂的主觀真意說下，被害人處分法益之意思有效的範圍最狹，處罰範圍最廣；而上述通

⁹⁶ 由本文此處的說明可知，本文前述貳、三、(三) 1.的分析中所指出的，對於詐欺罪被害人的錯誤之內容，採取(a)傾向的我國實務見解，在僅要求錯誤與財產處分之間有條件關係之點，與主觀真意說屬於相同的立場。

說的見解中，需視被害人處分法益之意思是被定性成阻卻構成要件該當性的構成要件要素或阻卻違法性之要素，才能決定被害人處分法益意思有效性的範圍，乃至處罰範圍廣狹；至於法益關係錯誤說的見解下，透過被害人的錯誤與法益是否有關連的判斷架構所得的有效範圍相對最廣，處罰範圍則相對最狹。

2. 詐欺罪中的法益關係錯誤說之運用

如本文前述對於我國實務的考察，以及所設定的課題所示⁹⁷，詐欺罪的成立判斷中，被害人的錯誤內容也需要有所限定，而考慮詐欺罪同樣具備被害人因錯誤處分自己法益的構造，筆者認為有關被害人因錯誤所為同意的有效性問題的諸說，可作為參考。問題在於，上述的各說當中，適用何說才能符合本文所欲達成的解釋論上目的，亦即對詐欺罪中被害人所生錯誤的內容，乃至詐欺罪的處罰範圍做較為合理妥當的限定？關於此一問題，基於以下的理由，本文認為法益關係錯誤說應該是較為妥當的理論上選擇。

第一，主觀真意說透過其適用下較廣的處罰範圍，確實有可能在法益保護上較為周延，但是事實上，從上述各例中可知，這種處罰範圍下，將會處罰行為人之行為導致被害人的誤認發生在「他人的法益」（上述【設例3】【設例4】【設例7】【設例8】）以及「形成自由意思決定的動機」（上述【設例6】）的情形。從理論的觀點來看，這種將他人的法益或決定動機代換至被害人因錯誤所為的法益處分意思有效性判斷的現象，將可能造成這些原本應該保護被害人的特定具體法益（例如生命、住居權、性自主、所有權本體）的犯罪類型之保護法益從被害人的法益，被代換成——甚至可能是他人的——其他法益，或者造成這些犯罪類型均成為保護一般性的意思活動或意思形成自由的犯罪，並不妥當⁹⁸。

⁹⁷ 參照本文貳、三、（三）。

⁹⁸ 參照：佐伯仁志（註3），頁59；山口厚，問題探究 刑法總論，頁81-82（1998

第二，雖然向來區分阻卻構成要件該當性的同意與阻卻違法性的承諾的見解下，處罰範圍相對地較為限縮，但是從其有效與無效的判斷標準繫於這種種形式上的體系論區別可知，事實上這種見解下處罰範圍的廣狹，將受到立法者在制定構成要件時是否將被害人同意作為構成要件要素的偶然而左右。如此一來，考慮到最近的刑法學基本上均將法益保護作為刑法的基本任務之一，則在欠缺法益保護上的實質理由的限度內，這樣偶然的形式上區分所決定出的處罰範圍本身似乎也難以找到可支撐的實質理由⁹⁹。特別是，倘若考慮到事實上構成要件的概念本身也可以理解為違法（乃至違法與責任）的類型化，則究竟維持這種形式的區分在理論上的意義與實益為何，即不清楚¹⁰⁰。

第三，上述的法益關係錯誤說下，處罰範圍固然相對較狹，然而在同說適用下可能將與被害人處分的具體法益無關的其他被害人法益乃至他人法益，或者意思形成的動機盡量排除於判斷外，對於被害人作為法益主體就自己法益之處分作成同意的具體範圍，具有較佳的釐清效果。並且，從刑罰權具體界限之形成的觀點來看，相較於上述的主觀真意說，這樣的判斷構造也有助於防止刑罰權的過度擴張，並確認刑法與其他法領域在法益保護領域的分工範圍¹⁰¹，有其意義¹⁰²。

年)。

99 參照：山中敬一（註73），頁927；林美月子，錯誤に基づく同意，收於：松尾浩也、芝原邦爾編，刑事法學の現代的狀況——內藤謙先生古稀祝賀，頁25（1994年）。

100 參照：佐伯仁志（註3），頁62；山口厚（註98），頁75-76。最近也有認為，當被害人基於自律處分其法益而為同意時，應認為立法者透過刑罰規定欲抑制的狀態（法益侵害的狀態）並未產生，因此不具備構成要件該當性。參照：三代川邦夫，被害者の危険の引受けと個人の自律，頁76（2017年）。

101 亦即，當超過刑法（罰）的極限時，即需透過適用其他制度或法律對法益的保護加以處理，而並非一味地嘗試透過膨脹刑法適用範圍的方式保護法益。參照：許恒達（註78），頁25。

102 參照：佐伯仁志（註3），頁61。

在此可能產生疑問，而需要進一步透過補充說明加以釐清的問題是，從被害人處分法益時所重視的事項為何的觀點來看，確實是不是不能認為，其實被害人可能在許多情形中，是依照該法益的處分是否符合自己主觀上最大利益的標準，來決定是否處分法益。例如，A向B謊稱為其檢查手臂皮膚，B承諾伸出手臂卻被抽血，B的承諾因為不知道會造成身體傷害而不符合其主觀上的最大利益；在A向B謊稱接受抽血可獲贈一只名錶，B因而承諾A為其抽血時，B的承諾也因為不知道無法獲贈名錶而不符合其主觀上的最大利益。換言之，在是否符合自己主觀上最大利益的觀點下，不論上述B的錯誤是不是和法益有關，都是作成了不符合其主觀最大利益的決定，依據這個觀點，倘若依照筆者所採取的「法益關係錯誤說」，在前一種情形要認為承諾無效，在後一種情形卻認為承諾仍然有效，則似乎並非自明。因此作為詐欺罪的解釋論，在法益關係錯誤說的選擇上，也需進一步說明其選擇的理論基礎為何¹⁰³。

關於此一問題，在此補充說明如下：

首先，筆者認為，對於一般被認為是刑法總則理論的法益關係錯誤說而言，透過刑法分則的解釋所掌握到的「法益」的內容如何，將會影響該說之下處罰的範圍¹⁰⁴。申言之，法益關係錯誤說的重點在與法益有「關係」的事項為何，而不是在界定「法益」本身。亦即，採取法益關係錯誤說判斷被害人因錯誤而處分其法益的情形，其處分法益意思之有效性時，須在（甲）法益的內容有所界定且（乙）就錯誤的內容也限定於與已經界定的法益內容（即（甲））有關的部分這兩個要件具備時，才能界定。在此意義下，當法益本身的內涵並未確定，或者包羅甚廣，或者過於一般、抽象

103 此部分的問題與有關抽血的兩則事例，是由匿名審查人之一所提出的寶貴意見。

104 參照：佐伯仁志（註46），頁108。

時，從理論觀點來看，即使使用法益關係錯誤說的主張，也會導致與不明確或過於廣泛的法益「有關係」的事項過於廣泛，進而使得被害人處分法益意思的有效性在極為廣泛的範圍內成為無效，從而肯定犯罪成立與刑罰的使用。

這種法益不明確或者過於廣泛導致使用法益關係錯誤說也無法有效限定處罰範圍的典型，即是過度地將行為人處分法益的意思決定之動機或意思形成自由納入法益內涵之中的情況。這是因為，以個人法益為例，幾乎所有個人法益的使用，行為人都可以設定一定的主觀目的或動機，這樣的目的或動機與個人主觀的利益有關時，其自由的行使確實有可能認為是法益的具體化。但是，有時行為人的意思決定，或意思決定的形成過程中，導致行為人為處分法益的決定之關鍵，未必都跟主觀利益有關係。亦即，即使是主觀上明知受損的法益處分，仍有可能為了（1）報恩（例如為了曾經幫助過自己的恩人捐助財物、為了報答養育之恩而為生病的父親捐贈骨髓或肝臟）、（2）單純的好惡（例如收到市價甚高的名牌餐具組，但是因為上面印有自己討厭的政治人物頭像，所以立即將餐具組砸毀）、（3）人際關係（例如為了能與心儀的對象交往，花錢贈送對方喜歡但自己其實不喜歡的美術畫作）而為之。

另一方面，倘若細究上述兩個關於抽血的例子中「主觀利益」的內容，應可認為包含了兩種不同的情況。第一種是被害人同意「檢查皮膚」但卻「被抽血」。第二種是被害人同意「抽血」且「被抽血」，但是要用「抽血」交換「名錶」。第一種情況中，倘若被害人一開始決定的是接受皮膚檢查，那麼被害人同意的範圍就僅有皮膚表面的檢查，在這樣的同意範圍中，一開始即沒有針對侵入性的抽血有任何同意。因此，這種情況之所以「不符合被害人主觀上的最大利益」，是因為被害人本來就對這種情況沒有同意，所以當然不可能有符合「被害人主觀上的最大利益」可言。第二種情況中，被害人有對「抽血」行為本身同意，因此在其同意是基於錯誤而做

成時，在決定這種基於錯誤之同意有效與否的同時，即必須檢討是否所有導致錯誤的要素，都可能導致法益處分的意思無效的問題。這時候，倘若採取法益關係錯誤說的立場，即會認為被害人所發生的錯誤存在於他人的財產法益是否要受處分，不是自己的身體法益，因此其處分自己身體法益即對於抽血的同意之有效性不受影響。

此處在理論上的重要問題即是，倘若毫無限定地包含各種可能影響最終的法益處分決定的因素，那麼確實可以得到法益關係錯誤說的理論對處罰範圍限定沒有必然關連的推論。但是，倘若如此，則——在法益內容相當地釐清的前提下——為何在某一法益處分意思有效性的檢討上，可以將與繫爭法益無關的要素納入考慮，同樣也成為難以回答的理論上問題。對這一問題，倘若要貫徹功利主義的觀點，認為即使是上述（1）報恩、（2）單純好惡、（3）人際關係的三種主觀目的設定，也都可算是符合法益持有者的「利益」，例如在（1）有維持親情或友情的利益、（2）有心情不受不喜歡的事物影響的利益、（3）有能與心儀對象交往的人際關係上利益，則這樣顯然是將刑法上的各種個人法益的犯罪都轉化為保護廣泛而抽象的「意思決定自由」的犯罪，而這正是刑法學上需要警戒並防止的情況。筆者認為此一問題的回答必須同時注意上述（甲）法益內容的界定、（乙）與法益內容的關連性的兩個要素需兼顧。並且，也必須注意，（甲）保護法益的內容界定的解釋論途徑並非法益關係錯誤論，而是在詐欺罪的解釋本身。這也是本文在法益關係錯誤說的檢討之前，先於前述內容中檢討詐欺罪的財產損害概念的原因。

依上述說明，將法益關係錯誤說運用於詐欺罪領域後，被害人受詐術後發生錯誤，並基於錯誤同意將財物交付給行為人的結

構¹⁰⁵，事實上與其他犯罪中被害人因錯誤而基於其意思為法益處分的構造相同，倘若認為其處分有效，則不構成詐欺罪，反之則成立詐欺罪。

從本文所重視的基本立場，亦即防止詐欺罪脫財產犯化之危險的觀點來看，在詐欺罪的領域運用法益關係錯誤說有以下的意義：

第一，從詐欺罪的保護法益是個別的財產，其法益主體為個人，並且一般均認為個人可以自由處分其法益的觀點來看，確實在被害人錯誤的內容上，只要是被害人設定或認為重要的任何事項發生錯誤，都可以將該等事項作為錯誤的內容加以考慮¹⁰⁶。但是，如同已於本文前述內容說明的¹⁰⁷，倘若真的貫徹個別財產說，並且在錯誤內容毫無限制時，當被害人所認為重要的事項與財產毫無關係時，詐欺罪的處罰條款將不再以保護財產為目的，而將進一步地轉為保護一般的人際關係，或一般的意思決定自由的規定，乃至為國家政策服務。這種情況，在本文作為研究對象的行為態樣，亦即被害人對於對待給付的內容有錯誤時，特別顯著。

第二，倘若關於被害人陷於錯誤的內容不加以限定為與財產法益有關的法益關係錯誤，則在被害人可以自由設定何種事項是交付財物時的重要考慮的情形，顯然詐欺罪的保護範圍將不僅有財產。例如青少年的身心健康之保護等公共政策，或者人際關係的交往的

105 參照：佐伯仁志（註3），頁102；山口厚，刑法各論，2版，頁267-268（2010年）；橋爪隆，詐欺罪成立の限界について，收於：植村立即判事退官記念論文集編集委員會編，植村立即判事退官記念論文集——現代刑事法の諸問題第1卷第1編：理論編・少年法編，頁176-179（2011年）。

106 在此必須強調的是，筆者固然認為，個別財產說的立場是對於詐欺罪的解釋論而言適合的基本出發點，但是筆者並不認為傳統的（形式的）個別財產說（亦即形式地只以有具體財物交付就馬上認為有財產損害）的見解是詐欺罪適合的解釋論。而是認為在個別財產說的基礎上進一步透過可以客觀化的經濟上重要目的等要件將財產損害內容加以限縮（參照本文貳、三、（三）1.與參、一、（二））。

107 參照本文貳、三、（三）1.之內容。

考慮也可能成為被害人同意交付與否的重要考慮。

但是，為何非財產保護脈絡下形成的公共政策，與非財產保護脈絡下的人際交往關係，需要以財產犯罪加以保護？的疑問，在理論上無法得到正當化之前，本文認為在詐欺罪的解釋上，毋寧應該避免本文前述「脫財產犯化」的危險，而從形式上涵蓋於詐欺罪文義範圍內的行為態樣中，再進一步實質地限定其成立範圍，使詐欺罪之保護範圍盡量維持在與財產有關的範疇內較為妥當。

在此可能出現的關連延伸理論問題是，既然詐欺罪的成立上，具有被害人基於錯誤同意將財物交付給行為人的結構，那麼，倘若認為被害人在交付財物時其主觀面需要有「交付意思」，那麼這樣的「交付意思」與財產處分的處分意思是否相同？又或者兩者是不同的問題¹⁰⁸？

關於此一問題，在此簡要說明如下：

交付意思在我國學說上也有稱為「財產處分的意識」¹⁰⁹或「處分意思」¹¹⁰者。在理論上，詐欺罪的構造中，是以（A）被害人受到詐欺，（B）陷於錯誤並（C）決定處分自己的財物後，（D）對於相對人透過交付行為移轉財物作為其客觀的歷程。（D）的行為即是上述的「交付行為」，其行為時移轉持有支配的主觀意思，即是「交付意思」。被害人交付之客體為財物的情況中，此處的（D）交付行為在理論上的重要功能，即是在劃定詐欺罪與竊盜罪的區別界線。亦即，詐欺罪與竊盜罪同屬於被害人財物的持有支配移轉給行為人的犯罪類型，而透過被害人基於受詐欺的意思而為的交付行為的要素，詐欺罪即可以與無此要素的竊盜罪相區別。亦即，除了透

108 此一問題為匿名審查人之一提供的寶貴意見。

109 參照：林東茂，刑法綜覽，增訂8版，頁2-164（2016年）。

110 參照：古承宗（註1），頁219-221。

過被害人處分法益之意思的有效性，理論上被害人進行交付行為時有無交付意思，也可能區別詐欺罪與竊盜罪。另一方面在客體為財產上利益時，也可區別不可罰的利益竊盜與可罰的詐欺得利罪¹¹¹。

從詐欺罪的條文解釋來看，以及詐欺罪本身以詐術至財產損害發生的連貫因果關係作為歸責基礎之觀點來看，客觀上需有交付行為這點，基本上並無疑問。不過，被害人交付財物時，是否需對自己交付財物的內容、範圍有明確的認識，亦即是否需具有「交付意思」，學說上並非沒有不同意見。在文獻上，至少有（甲）無意識之交付行為說（只要被害人知悉自己在交付某種財物，且外觀上有交付的行為即可）、（乙）嚴格的交付意思必要說（被害人需要具體認識交付之財物的詳細內容）、（丙）緩和的交付意思必要說（被害人無需認識到具體的財物內容，但需要認識到自己在移轉之財物的種類）三種見解¹¹²。這三種見解，主要可透過以下幾種交付意思成為問題的情形說明其運用上的異同：

第一，A在魚市場看到一盒外面貼有「秋刀魚50條」箱子，細數後發現其中其實有秋刀魚60條，於是向賣魚攤販B指定要買該盒秋刀魚，B因買賣忙碌，並未細數即收受A所支付的50條秋刀魚的價金，之後再拿起該盒（裝有60條秋刀魚的）魚貨交給A。

第二，A在魚市場看到一盒外面貼有「秋刀魚50條」箱子，但發現其中多了兩條高價石斑魚，於是向賣魚攤販B指定要買該盒秋刀魚，B因買賣忙碌，並未細數即收受A所支付的50條秋刀魚的價

111 參照：簡要說明，可參照：山口厚（註105），頁256；高橋則夫，刑法各論，3版，頁322（2018年）；井田良，處分行為（交付行為）の意義，收於：西田典之、山口厚、佐伯仁志編，刑法の争点，頁182（2007年）。因為我國刑法學界的現況下，在詐欺罪的領域中，對交付行為與交付意思的討論並非充分，所以以下的內容筆者將援用詐欺罪規定與我國類似的日本刑法學論述作為說明的參考與依據。

112 理論概況的簡要說明，可參照：佐伯仁志，詐欺罪（2），法學教室，373号，頁114-115（2011年）。

金，之後再拿起該盒（裝有50條秋刀魚與2條石斑魚的）魚貨交給A。

第三，A在魚市場A在魚市場看到一盒外面貼有「秋刀魚50條」箱子，但發現其中多了賣魚攤販B之前因進貨而先脫下放置的裝滿數萬元現金的錢包，之後B回來後，A即向B表示要購買該盒秋刀魚，B一時不察，即收受A所支付的價金，並將該盒（裝有50條秋刀魚與B之錢包的）魚貨交付給A。

倘若採取上述（乙）說，則基本上上述三個例子中，針對第一例中行為人多取得的10條秋刀魚，第二例中A多取得的兩條石斑魚，以及第三例中A所取得的B之錢包，因被害人在交付該盒魚貨時，對此等財物均無認識，所以均應成立竊盜罪。若採取上述（甲）說，則就A取得上述的三種財物應成立詐欺罪。另外，採取（丙）說，文獻上有認為僅就第一種情形成立詐欺罪，但就第二與第三種情形成立竊盜罪，但也有認為三種情況均成立詐欺罪者。從上述的說明即可知，一方面交付意思本身是否必要，在學說上未必有定見，另一方面，就算是認為交付意思有必要，則交付意思的實質，其實是對於財物的持有支配將要移轉於他人的一種事實上狀態變動的認識，與被害人決定要處分法益，甘受法益侵害的意思，並不完全相同。因為理論上，交付意思也應該以決定處分法益的意思存在為前提¹¹³。

考慮到（1）一方面交付意思與處分法益的意思並不完全相同；（2）交付意思是否必要的問題，在文獻上、理論上也還無定論；（3）從上述三個交付意思成為問題的典型情形來看，交付意思會成為疑問的時候，事實關係的特徵是被害人對自己交付給行為人的財物本身有不正確或不完全的認識，但是本文中我國實務上成為

113 以上說明，是參考：佐伯仁志（註112），頁114-115；橋爪隆，詐欺罪における交付行為について，法学教室，436号，頁81-82（2017年）。

問題的情況幾乎都是被害人清楚地認識自己交付的財物，卻對於行為人要提供的對待給付內容有錯誤之情形；(4) 本文的問題意識是針對我國實務隱含的擴張詐欺罪處罰之問題提供理論上可能的解釋方向，並非全面性地檢討詐欺罪的所有構成要件要素等各點，為免爭點逸散，本文以下內容中，即無法再進一步深入處理交付意思與處分法益之意思的異同問題，而需留待日後再行研究。

三、詐欺罪構造的理解

在詐欺罪財產損害的問題上採取功能的財產概念，並且透過法益關係錯誤說限定被害人所生錯誤的內容後，下一個在理論上需處理的問題，即是這樣的理解對於詐欺罪的構造有如何的影響？

筆者認為，從法益關係錯誤說的觀點，考慮到被害人的財產損害是因為其基於錯誤所為的處分造成，則在這樣的關係下，詐欺罪的財產損害與被害人所生的錯誤內容之間，應該盡量地對應而有一致性。這樣的一致性的內容，從法益關係錯誤的觀點來看，是指被害人的錯誤需與——本文前述的功能的財產概念下的——財產法益有關¹¹⁴。具體而言，在詐欺罪的解釋上，(1) 關於被害人所生的錯

¹¹⁴ 學理上另外也有從詐欺罪的欺罔行為必須要具備以「平均的消費者」為標準的客觀的欺罔行為適性者，參照：富川雅滿，詐欺罪における被害者の確認措置と欺罔行為との関係性（三・完）—— 真実主張をともなう欺罔をめぐるドイツの議論を素材として，法学新報，122卷7・8号，頁244-248（2016年）。同旨趣の見解，可參照，葛原力三（註47），頁234-235。

另外可以補充說明的是，倘若採取前述我國實務與學說的「主觀真意說」，那麼顯然難以限制詐欺罪的處罰範圍。學說上固然也有進一步從是否可認為該錯誤的內容「重要」的觀點嘗試限縮詐欺罪的欺罔行為，進而限縮處罰範圍者（參照：曾淑瑜（註1），頁166。學理上同旨趣的主張，可參照：木村光江，「欺く行為」における「重要な事項」の判断基準，收於：井田良等編，山中敬一先生古稀祝賀論文集（下卷），頁203-206（2017年）），但是，一方面倘若該「重要」性的判斷標準在於是否可能影響被害人財產時，則這樣的主張即與法益關係錯誤的見解無太大差異；另一方面，這樣的「重要性」標準，在被害人將國家政策，或者行政上的目的當作交易上重要的考慮時，也同樣難以限制詐欺罪的處罰範圍。事實上，在比較法上，例如日本最高裁判所最近的刑事判例，即可見到國家的政策滲透進入詐欺罪領域的現象。亦

誤，應該限定在詐術行使的內容中與財產法益有關的事項，（2）關於財產損害的有關事項，則是以被害人的財產損害為內容，其存否則可透過【A】客觀上，【B】從被害人所為的個別的財產給付，【C】是否能體現其對被害人有經濟上重要的目的等要素來觀察。在這樣的理解下，（2）的層面的要素中，特別是【C】的要素是否存在，即會直接影響（1）的層面的內容。

不過，法益關係錯誤說的立場下，在這樣使被害人的錯誤內容乃至詐術行使的內容與詐欺罪的財產損害連動之後，即會產生向來被我國刑法學的通說認為是詐欺罪中獨立的構成要件要素的財產損害，被納入詐欺罪的詐術行為要件下檢驗，而不再是獨立的構成要件要素的現象。這樣的現象應是否可能合乎我國詐欺罪條文的文義，即成為下一個問題。

筆者認為，上述對於詐欺罪構造的掌握方式進行調整，在理論上應有可能。理由在於：

即，在日本強力地推動排除幫派的政策下，各地方政府均制定條例，而在這些條例施行後，不論是銀行這種經濟機構，甚至是高爾夫球場等休閒場所，都盡量地避免、拒絕幫派分子或幫派關係人的使用。在這樣的背景下，【判例1】最決平成26（2014）年3月28日刑集68卷3号646頁的最高裁判所裁定，在被告身為幫派份子，與友人一同前往高爾夫球場打球，在入場前填寫球場方面所提供的確認表格時隱瞞自己為幫派份子的身分，並在依照球場所定價目表支付價金後入場打球的事實關係下，認為從（1）幫派成員使用球場設施會造成球場客人減少，影響球場信用，因此入場使用之人是否為幫派分子是球場經營上重要事項、（2）本件球場於入會時即有誓約書，且有電子查詢系統可查詢預約之客人或其同伴是否有幫派身分、（3）本件球場若知悉被告身分，即不會提供球場設施供其利用等事實，可肯定利用人是否有幫派身分是「球場工作人員在決定是否提供球場設施予其利用的判斷基礎上的重要事項」，被告對此欺瞞是詐欺罪的欺罔行為，而因此使用球場設施，雖然有支付價金，但仍構成日本刑法第246條第2項的詐欺得利罪；【判例2】最決平成26（2014）年4月7日刑集68卷4号715頁的最高裁判所裁定，在銀行所提供的各項確認表格中不表明自己為幫派成員，並申請開戶而取得存摺與金融卡的事實關係下，認為既然開戶者不屬於幫派成員是成為銀行交付財物決定之基礎的重要事項，則被告隱瞞自己為幫派成員之身分申請開戶是詐欺罪的欺罔行為，而收受存摺與金融卡構成詐欺取財罪。

第一，詐欺罪做為財產犯罪，則其以財產損害作為成立之要件，是相當自然的理解，已如前述。但是，如同已有學說指出的，我國刑法的詐欺罪規定中，並無「財產損害」字樣¹¹⁵，從而「財產損害」的要件在詐欺罪結構的定位上，雖然並非不能如同通說一般將其作為獨立的不成文構成要件要素加以掌握，但是仍難回應條文上根據何在的質疑¹¹⁶。因此，若考慮到財產損害有無的判斷問題上扮演重要角色的財產處分目的不僅在財產損害的領域可以發揮功能，也可以在詐術的領域、被害人的錯誤的領域發揮功能，如能在條文有規定的詐術行使下，考慮詐術內容時將其可能造成的財產損害內容納入考慮，亦即將被害人所生錯誤的內容限定於與其財產（財產損害）有關者，則不僅在實質上，詐欺罪成立時考慮要件並無差異，也與條文文義較為貼近¹¹⁷。

第二，刑法第339條第1項的詐欺罪僅規定「以詐術使人將本人或第三人之物交付」（粗體字為筆者所強調），而通說在理解上，則是將詐欺罪理解為保護整體財產的犯罪，將整體財產的減損認為是財產損害，從而通說的整體財產損害概念即與「物」的文義不一致，這或許也是我國通說，將財產損害在詐欺罪的構造上定位為獨立的構成要件要素的背景。通說理論的背景，儘管從理論上可以理解，並且也可認為一貫。但是，倘若透過本文前述的分析與檢討，在詐欺罪的解釋上，可認為財產損害仍應以個別財產的處分交付可否在客觀上體現對於被害人於經濟上重要的目的為內涵¹¹⁸，則在本

115 參照：陳子平（註1），頁567。

116 參照：佐伯仁志（註46），頁107；山口厚，詐欺罪に関する近時の動向について，研修，794号，頁8（2014年）。

117 為免誤會，在此必須強調的是，這樣的理解並不表示不需要在詐欺罪的成立要件檢討中檢驗財產損害，而是將財產損害還原至現有的詐欺罪構成要件要素的項目下。

118 在此意義下，與我國刑法學的通說不同，筆者認為詐欺罪是一種保護個別財產的犯罪。與我國刑法詐欺罪規定相近（沒有規定財產損害要素）的日本刑法學的通說，也認為詐欺罪是保護個別財產的犯罪（參照：山口厚（註

文所採的理論背景下，關於財產損害於詐欺罪構造中的定位上，即不需與通說相同。毋寧將其作為詐術行為的內涵之一部¹¹⁹，較為自然。

因此，在這樣的考慮下，筆者認為詐欺罪的詐術行為，是有製造被害人財產損害之危險的行為¹²⁰，其所引起的被害人錯誤即是這種財產損害危險的體現，而被害人的財產損害，則是同一財產損害危險的現實化。法益關係錯誤說在詐欺罪的解釋上，具有能夠將這樣的架構順利串連的功能，有其重要的意義¹²¹。在本文的主張之下，應認為倘若與財產損害無關的事項，即無法認為是詐術的內容，並且被害人即使對此發生錯誤，也無法認為其錯誤是對於詐欺罪成否有意義的被害人之錯誤。

當然，關於本文此部分的主張，可能的疑問或許在於：

第一，這種將詐欺罪的財產損害要素整合入詐術與陷於錯誤的解釋論，是否過度拘泥沒有財產損害文字的詐欺罪條文¹²²？

第二，通說理解下，「詐術」僅需以傳達不實訊息為內涵，內容並無限定，且「陷於錯誤」同樣沒有條文規定，但一般均不否認其為詐欺罪的構成要件要素，因此應如何如本文所主張，將「陷於錯誤」認為是「詐術」的內涵¹²³？

第三，倘若不採取「財產損害」這個不成文的構成要件要素，那麼在具體的情況中，是否可能導致不妥當的結論？例如，A出售

116)，頁7)。

119 參照：佐伯仁志（註61），頁106；山口厚，コメント（佐伯仁志，詐欺罪の理論の構造），收於：山口厚等編，理論刑法学の最前線Ⅱ，頁137（2006年）。

120 參照：葛原力三（註47），頁235、238。

121 參照：山口厚（註119），頁137。

122 此為匿名審查人之一提供的寶貴意見。

123 此為匿名審查人之一提供的寶貴意見。

人工皮草大衣，卻謊稱是真皮草大衣，X受騙花5萬元購入，而該人工皮草大衣市值亦為5萬元。此時，A的詐術和X的錯誤認知，都是大衣材質此一與經濟價值有關的事實，符合「行使詐術」、「陷於錯誤」而「交付自己之物」的要件，但是如果不附加「財產損害」要素，依據筆者所採取的個別財產概念，即使再採取本文上述對於詐欺罪構作的理解，似乎必須認定上述人工皮草設例的A成立詐欺罪。如此一來是否有處罰範圍過大的問題¹²⁴？

關於上述的三個問題，在此簡單說明本文的立場如下：

關於第一個問題，首先，如同眾所周知的，財產犯罪中有「對整體財產之犯罪」與「對個別財產之犯罪」的分類。前者以被害人的總資產的減少狀況存在為成立前提，後者以被害人交付或被奪取的財物本身為損害，不需考慮總資產是否出現減少的狀況，這是我國目前的通說均承認的基本區分¹²⁵。同時，我國通說進一步也將詐欺罪認為是一種「對整體財產之犯罪」，因此也都認為詐欺罪需要考慮被害人的總資產的減少狀況，作為詐欺罪「（整體）財產損害」的內容¹²⁶。由於被害人僅交付財物還不能立即認為是詐欺罪的財產損害，並且，詐欺罪也未如背信罪般對（總資產減損的意義下的）財產損害有明文規定，倘若要尋求這種整體財產損害在解釋上的定位，自然只能將其作為不成文的構成要件要素，已如前述。

然而，與上述的通說立場相對地，本文的基本立場是認為被害人交付的物本身就可認為是具體實現的財產損害，但是仍要進一步再透過交易目的的考慮限縮詐術及陷於錯誤等要件，同時限定財產損害的範圍。則在本文這樣的解釋論基本立場下，依附詐欺罪已經

124 此亦為匿名審查人之一提供的寶貴意見。

125 代表性的說明，參照：蔡聖偉，概說：所有權犯罪與侵害整體財產之犯罪（上），月旦法學教室，69期，頁53-54（2008年）。

126 代表性的說明，參照：蔡聖偉（註42），頁49。

有的構成要件要素之解釋毋寧是解釋論上較為自然的途徑。倘非如此，則在詐術、陷於錯誤、交付財物等要件之解釋已可能涵蓋財產損害的情況下，必須要另外再以不成文構成要件要素的型態再檢驗財產損害，從本文立場下也並非一貫的理論架構與理論演繹。在此考慮下，筆者並非單純拘泥條文文字，而是在解釋上採取盡量將詐欺罪財產損害整合入已有的成文構成要件要素的途徑。

關於上述第二個問題，則可分以下幾點說明。

首先，我國刑法第339條第1項的客觀構成要件內容是「以詐術使人將本人或第三人之物交付」。倘若考慮：（1）從詐欺罪與一般犯罪均相同，需要以結果的發生與行為之間有因果關係作為歸責基礎；（2）「以詐術使人將本人或第三人之物交付」的文義下，「交付」的構成要件要素之描述還需顧及「使」的文義，亦即詐欺罪中，財物交付是使用詐術後「使～交付」的情況，則即使如我國通說見解，僅將詐術定義為不實訊息，但在此一文義下，詐欺罪的被害人既然會因為不實訊息交付財物，則其交付行為，解釋上即必須是基於錯誤所為的交付等各點，那麼要將因果上相續於詐術的被害人陷於錯誤與詐術的內容相連結，在文義上並非不可能。

其次，本文問題意識內涵的一部分，即是在承認詐欺罪有「（A）詐術行使——（B）被害人陷於錯誤——（C）被害人基於錯誤交付財物——（D）財產損害」的這種貫穿的因果構造下，嘗試將符合詐欺罪作為財產犯罪的財產損害概念實質地納入此一構造中，不將財產損害本身當做獨立的構成要件要素。並且，在這樣的想法下，在上述架構中存在的（A）（B）（C）要素的解釋上，透過將（A）（B）（C）的要素均限定在與財產損害有關者的方式，提出雖與我國通說不同，但理論上有可能的解釋途徑。因此，本文的重點即是在現有的文義、概念、架構之前提下，探求理論上還有可能，但較少受到目前學說關注的解釋論，並非新創用語或概念。

關於上述第三個問題，從筆者所主張的法益關係錯誤說的觀點，確實大衣的材質是否是真皮草或者人工皮草這一事實會直接影響大衣價格高低，在此前提下，應認為上述例子中X所生的錯誤是與其處分之財產法益有關的錯誤。因此，在本例中，行為人A的行為有成立詐欺罪的餘地。上述疑問的根源或許在於，被害人X實際上花費5萬元，但也得到價值5萬元的對待給付，兩者既然相當，則即使被害人對於可能影響價值的要素有錯誤，為何仍必須要認為成立詐欺罪？並且，上述的疑問也可認為是反映另一個理論上不同的基本立場，亦即可以在這種檢驗詐欺罪是否成立的情形中，透過檢討不成文的「財產上損害」概念，排除詐欺罪的成立。倘若上述第三點的疑問的核心在此，則對此筆者認為必須要在此釐清以下兩點：

首先，筆者並非主張詐欺罪不必檢討財產損害，而是主張詐欺罪的財產損害可能以個別的財產損害為前提，但是將財產損害設定為對被害人而言帶有客觀上可觀察之經濟上重要意義者，而不需要是整體財產損害。同時，筆者認為這樣的財產損害概念可透過限縮「詐術」和「陷於錯誤」等概念來包含入詐欺罪的構造中。

其次，上述購買皮草的案例既然是以交易為內容的詐欺行為類型，則要檢討財產損害時，需要比較的對象並非（甲）被害人所實際交付的財物，以及（乙）實際所得的財物。而是（甲）被害人實際交付的財物，以及（丙）被害人「透過交付財物想要得到的財物」。只有比較（甲）與（乙）時固然並無落差，但是當比較對象是（甲）與（丙）時，兩者即生落差。在此意義下，筆者認為上述第三個問題中的案例，仍有可能成立詐欺罪。這種落差在被害人交付財物的同時欲取得一般行情上更為高價的商品時會更為顯著。例如將上述購買皮草案例的商品修改為世界知名的勞力士手錶，亦即想要買到勞力士名錶的X花了5萬元購買了一個行情亦為5萬元的假錶的情況中，透過與本文同樣的考慮，也會成立詐欺罪（重點不是

假錶對X沒有用，而是X想透過5萬元貨款的支付取得真正的勞力士手錶）。倘若可以接受這樣的結論，則對於上述的購買皮草案例，也應認為有詐欺罪成立的餘地，始為一貫。

最後，於此可附帶說明的是，依照筆者所採取的見解，在雖有個別財產之給付，但對被害人並無經濟上重要之目的，從而無法認為被害人受有財產上損害的情形，例如前述本文參、一、（二）中所提及，戀愛或結婚詐欺的情形，倘若被害人提供資金，是單純因為對於結婚的期待，或者戀愛感情發展的期待而為，則此時透過財產損害的否定，也將否定詐術的構成要件要素之該當。此即與將財產損害作為獨立的構成要件要素之見解——在否定詐欺罪成立的理由上——有所不同。

肆、結論

在以上的內容中，筆者先以我國詐欺罪實務為素材，先後考察了詐欺罪中的被害人錯誤之內容，以及被害人的財產損害之內容，了解前者的部份，我國實務存在著（a）傾向較為嚴格地從與財產的關連性加以考慮的立場（本文前述【事例1】【事例4】【事例5】的判決），也有（b）傾向僅考慮——不區別被害人的錯誤內容——以被害人之錯誤與交付財物有無條件關係的立場（本文前述【事例6】【事例10】【事例11】的判決）；後者的部份，則有採取所謂（甲）個別財產概念者（上述【事例1】【事例12】的判決），也有採取（乙）整體財產概念者（上述【事例7】【事例13】的判決）。並且，透過本文的分析，可以發現因為解釋論上實務採取上述何種立場與概念，並無特別的限制，所以倘若在實務採取上述（b）＋（甲）的立場時，無法限定而擴張的詐欺罪處罰範圍，將導致詐欺罪「脫財產犯化」的危險。

為了對應實務所存在的危險，本文透過對於詐欺罪的財產損害內容的探討，認為可以以個別的財產說為解釋論的出發點，但是採取「功能的財產概念」加以修正。在這樣的概念中，詐欺罪財產損害有無的判斷標準應為：【A】客觀上，【B】從被害人所為的個別的財產給付，【C】是否能體現其對被害人有經濟上重要的目的。

本文也透過對於詐欺罪被害人之錯誤內容應如何限定之問題的探討，認為可以援引學理上被害人同意或承諾領域中的法益關係錯誤說，進一步將被害人的錯誤限定於與詐欺罪財產概念有關者。並且，本文在這樣的理解上，進一步認為行為人行使詐術的內容、被害人錯誤的內容，以及被害人的財產損害之內容，應該有對應、一致的關係，同時主張在我國的條文解釋上，可將被害人的財產損害納入行使詐術乃至陷於錯誤的解釋當中¹²⁷。

¹²⁷ 在此可附帶說明的是，刑法第339條第2項就以詐術得財產上不法之利益或使第三人得之利益的情況，也加以處罰。解釋上，第339條第2項的規定下，應可認為被害人是因錯誤移轉財產上利益，而受到損害。在此，第339條第2項的規定下同樣需要財產損害一事與同條第1項規定在解釋上並無不同。不過，考慮到同條第1項的「物」一般是指有體物，本身較無問題，第2項的「利益」之內容為何即有進一步探討的餘地。我國學理對此部分的著墨較少，若援用條文文義與我國幾乎相同的日本刑法學理論來說明，則理論上可能有四種解釋的方式：

第一，認為第339條第2項的「利益」包含一切財產上利益，包括勞務提供、權利取得、債務免除，並且這些利益不僅僅是法律上的利益，即使是對於債務清償的事實上遲延也可以算是利益（這是日本傳統通說的見解，例如：藤木英雄，刑法講義各論，頁310-311（1976年）；大塚仁等編，大コンメンタール，第13卷（第246條～第264條），2版，頁125-126（高橋省吾執筆）（2000年）等參照）。

第二，認為如果是以財物作為終局目的的情況，即使中間有債權債務的發生，也應論以第1項的詐欺取財罪。至於以利益取得為終局目的的情況中，則主張第339條第2項的解釋必須要有一定的限定，至少要能與第1項的財物有足以等同視之的具體性與確實性。以債權為例，如僅是單純延後支付等事實上利益，並不能認為是詐欺得利罪的「利益」，必須要這種事實上的延後支付有導致債權價值減少等具體情況才能肯定詐欺得利罪的「利益」存在。（例如：西田典之著、橋爪隆補訂（註40），頁207參照）。

第三，認為（包含竊盜罪在內的）所有財產犯罪都是整體財產犯罪，因此詐欺得利罪是整體財產犯罪（參照：林幹人（註41），頁142-146）。

最後，在關於詐欺罪的處罰範圍的現實問題上，通過本文以上的檢討，再回顧我國的刑事實務，可根據本文的解釋論立場，透過對於本文曾經舉出的我國實務事例的具體運用，提出以下的數點解釋上的歸結：

第一，是可肯定詐欺罪成立的部分。

在本文前述【事例1】的判決中，X在【A】客觀上，【B】匯款美金6百萬元至A指定之帳戶，【C】此一匯款是為了投資外國不動產，在進行投資的意義下，可認為對於X而言有經濟上重要之目的，因此此一經濟上目的無法實現的情況下，可認為X受有財產損害。除此之外，X之錯誤所在，是A等人宣稱要投資外國不動產但卻投資我國不動產，自然是屬於與其財產權即資金用途相關的法益關係錯誤。在此意義下，依照本文見解可以肯定詐欺罪的成立。

在本文前述【事例4】的判決中，X在【A】客觀上，【B】支付新臺幣1千零70萬元予A等人，【C】此筆金額是為了購買狀態正常之房屋。在進行不動產交易的意義下，可認為對於X而言有經濟上重要之目的，因此在本件房屋因地震損壞、嚴重傾斜與被標示為危險建築物的事實關係下，可認為X之經濟上目的無法實現，受有財產損害。除此之外，X之錯誤所在正是房屋有無損壞、傾斜與是否為危險建築物等部分，是影響房屋價值即支付價金高低的法益關係

第四，採取區別說，認為對財物的詐欺罪是個別財產犯罪，認為對利益的詐欺罪則是整體財產犯罪（例如：団藤重光，刑法綱要各論，3版，頁546（1990年）參照）。

從上述的內容可知，倘若與我國詐欺罪規定構造與內容幾乎相同的日本詐欺得利罪解釋上也多樣的可能性，則基本上我國詐欺得利罪究竟應採何種理解，仍需進一步經過檢討才能確定。這也是為何筆者並未將此部分納入本文之範圍的原因。不過，在此值得指出的是，從上述日本學理中存在將每筆個別具體的利益當成是詐欺得利罪客體的第一說，以及更進一步透過具體條件讓詐欺得利罪的利益能與第1項的財物相當的第二說的見解可知，即使客體為利益，也不當然會推導出刑法第339條第2項詐欺得利罪在性質上是整體財產犯罪的結論。

錯誤。在此意義下，依照本文見解可以肯定詐欺罪的成立。另外，本文前述【事例5】的判決中，被害人所購買之房屋為凶宅，即無法達到其欲購買正常房屋之經濟上重要目的，因此也可以依照與上述內容同樣的理由，肯定詐欺罪的成立。本文前述【事例13】的判決中，被害人所購買的房屋為因氣爆等公安原因一部不能使用的海砂屋，即無法達到其欲購買可使用海砂屋範圍全部之經濟上重要目的，因此也可以依照與上述內容同樣的理由，肯定詐欺罪的成立。

在本文前述【事例6】的判決中，被害人【A】客觀上，【B】支付價金，是【C】為了購買經政府公告許可添加之製造豆花等食品的添加物，在進行生產製造加工食品（商品）的意義下，可認為是經濟上重要的目的。因為食品添加物如非經公告許可使用，將影響被害人生產產品之用途（因為無法用於所生產產品中），所以本件被害人購得未經公告許可添加之物，即無法達成其經濟上重要之目的，因此可以肯定詐欺罪的財產損害。並且，有無經公告許可添加，既然是生產食品為業之被害人決定是否支付價金的前提，對其發生錯誤即屬法益關係錯誤，從而可以肯定詐欺罪的成立。

在本文前述【事例8】的判決中，X在【A】客觀上，【B】支付A費用，是【C】為了要委任律師進行與訴訟有關之事務，在支付專業人士報酬的意義下，可認為是經濟上重要的目的。但是A既然並非律師，所為也非專業，則在此意義下，A交付之財物無法達成其經濟上目的，因此可以肯定詐欺罪的財產損害。並且，有無律師資格在本件是交付律師委任費用的必要前提，因此X對此發生之錯誤即可認為是法益關係的錯誤，從而可以肯定詐欺罪的成立。

在本文前述【事例11】的判決中，被害人在【A】客觀上，【B】交付小額現金，是【C】為了要捐助受災的災民，在給予需要經濟上援助之人金錢捐助的意義下，可以認為有經濟上的重要目的。但是既然A等人收款後並未將款項用於賑災，則被害人交付財

物的經濟上目的即無法達成，因此可肯定詐欺罪的財產損害。並且，是否要用於賑災是交付現金的必要前提，因此被害人對此發生之錯誤可認為是法益關係的錯誤，從而可以肯定詐欺罪的成立。

第二，是應否定詐欺罪成立的部分。

在本文前述【事例2】的判決中，提起自訴之X在【A】客觀上，【B】支付被告新臺幣7百萬元，【C】此一匯款是以有買回條款為條件而投資靈骨塔位，在投資的意義下，可認為對X有經濟上重要之目的。但是，考慮到一方面本件中的靈骨塔位的存在並非虛偽，並且買回條款的簽訂是X與本件A等人間協議而成，同樣也非虛偽，因此難以認為X的經濟上重要之目的無法達成。在此意義下，詐欺罪之財產損害即應否定，同時也應否定被害人發生錯誤。從而應否定詐欺罪之成立。

在本文前述【事例3】的判決中，X3在【A】客觀上，【B】借款給A，並且依照法院之認定，是【C】為透過借款抽取佣金，在賺取佣金增加自己所得收入的意義下，可認為是經濟上重要的目的。因為X3可透過賭場抽取佣金，加上本件法院認定A有積極還款之行為，所以難以肯定X3的經濟上重要目的無法達成。在此意義下，詐欺罪之財產損害即應否定。並且，即使A平時有使他人誤認自己為知名企業少東的虛榮行為，但是在本件法院的事實認定中，無法認為A於本件借款行為時有利用他人誤認自己身分以致於誤認自己清償能力的事實，所以也難以認為本件被害人於借款時有關於財產法益上的法益關係錯誤。從而應否定詐欺罪之成立。

在本文前述【事例7】的判決中，被害人在【A】客觀上，【B】支付豆芽菜之價金，【C】此一支付價金之目的是為了購買作為料理用的食材，在購買食材的家庭經濟的意義下，可認為是對被害人等經濟上重要之目的。但是，考慮到本件添加物本身屬於可以合法使用於食品漂白、抗氧化的添加物，本件A等人所用之用途也

是豆芽菜之漂白，因此以相當之價格購買本件之豆芽菜難以肯定經濟上重要的目的無法達成。在此意義下，詐欺罪的財產損害即應否定¹²⁸。並且，如本件判決所示，由於行為時法令上對於市場之散裝蔬菜等商品之添加物等內容必須告知消費者的義務，故並無行使詐術之情形，被害人也未發生錯誤。從而應否定詐欺罪之成立。另外，本文前述【事例12】的判決中，在（1）被告所添加的油品對人體健康無害、（2）被害人等購買油品之目的是為食用，但並不限定在特定品項（例如純橄欖油）的油品、（3）販售價格也非不相當地過高的限度內，應同樣可認為難以肯定經濟上的重要目的無法達成，從而應否定詐欺罪的財產損害。

在本文前述【事例9】的判決中，被害人在【A】客觀上，【B】支付A議員與立法委員的事務費用與薪資等，是【C】為了給付執行其職務之必要費用與報酬，在支付必要費用與報酬的意義下，可認為有經濟上的重要目的。因為本件A確實有進行議員與立法委員之職務，所以難以肯定此一經濟上的重要目的無法達成。至於本件被害人發生錯誤之所在，是在A之國籍，即與上述經濟目的無直接關連，因此難以認為是法益關係錯誤。從而應否定詐欺罪之成立。

在本文前述【事例10】的判決中，X在【A】客觀上，【B】為A支付超過新臺幣2百萬元之款項，是【C】為了與X結婚。由於結婚的意思有無，固然屬於人際關係上的重要事項，但難以認為是經濟上的重要目的。因此本件即難以肯定詐欺罪的財產損害，並且X對A有無結婚意思之錯誤也難以認為是法益關係錯誤¹²⁹。

128 儘管同樣是有關食品添加物是否虛偽的問題，相較於前述【事例6】之判決中被告是將未公告核准作為添加物的化學物質販售給食品加工的廠商，本件被告則是將有公告核准作為添加物的化學物質用於豆芽菜，兩者在此意義上即有不同。

129 另外，關於本文前揭註114所舉的兩則日本最近受到矚目的最高裁判所刑事判例，因為日本刑法學的研究本身並非本文的主題，所以僅能於此簡單地說明

倘若依照本文之立場應如何理解此二裁判。首先，關於【1】最決平成26（2014）年3月28日刑集68卷3号646頁，因為本件中被害人即高爾夫球場【A】客觀上，【B】提供球場勞務，【C】是為了讓支付使用費用的客人能夠使用該球場，在提供服務換取費用作為經營內容的意義下，可認為是有重要的經濟上意義。但是本件被告既然支付使用費，則難以認為被害人經濟上的目的無法達成，因此應否定財產上損害的發生。另外一方面，被害人發生錯誤之所在是被告有無幫派成員之身分，而該身分的判斷固然有其治安政策上的意義，但與上述經濟上的目的並無直接的關連，從而在被害人之錯誤也無法認為是法益關係的錯誤。其次，關於【2】最決平成26（2014）年4月7日刑集68卷4号715頁，也應該認為被害人即銀行【A】客觀上，【B】交付存摺、金融卡，【C】是為了讓開戶名義人本人能夠使用該帳戶存放或領取款項，在存放款等業務原本即屬銀行之事業內容的意義下，可認為是有經濟上重要的目的。考慮到本件的帳戶既然作為被告自己存放款與領取款項使用，則該經濟上重要的目的即難以認為無法達成。因此應否定財產損害。另一方面，被害人發生錯誤之所在是被告有無幫派成員之身分，而該身分的判斷固然有其治安政策上的意義，但與上述經濟上的目的並無直接的關連，從而在被害人之錯誤也無法認為是法益關係的錯誤。在此意義下，應否定詐欺罪之成立（從刑法與其他法領域分工之觀點下的相同主張，可參照：佐伯仁志（註61），頁113）。

參考文獻

1. 中文部分

- 王皇玉(2013), 強制手段與被害人受欺瞞的同意: 以強制性交猥褻罪為中心, 臺大法學論叢, 42卷2期, 頁381-432。
- 王效文(2010), 職棒比賽放水詐賭的刑事責任, 月旦法學教室, 88期, 頁89-95。
- 古承宗(2018), 刑法分則: 財產犯罪篇, 臺北: 三民。
- 甘添貴(1980), 被害人之承諾與違法性, 軍法專刊, 26卷12期, 頁9-14。
- (2014), 刑法各論(上冊), 修訂4版, 臺北: 三民。
- 余振華(2010), 刑法違法性理論, 2版, 臺北: 自版。
- 吳耀宗(2008), 詐欺罪詐術行使之解析, 月旦法學雜誌, 163期, 頁50-64。
- (2013), 被害人受騙之承諾, 月旦法學教室, 126期, 頁27-29。
- 林大為(2013), 論詐術性交罪——兼論「宗教騙色」案件之認事用法問題, 軍法專刊, 59卷5期, 頁108-137。
- 林山田(2006), 刑法各罪論(上冊), 5版, 臺北: 自版。
- (2008), 刑法通論(上冊), 增訂10版, 臺北: 自版。
- 林東茂(1998), 詐欺罪的財產損害, 中央警察大學法學論集, 3期, 頁199-210。
- (2016), 刑法綜覽, 增訂8版, 臺北: 一品文化。
- 林書楷(2018), 刑法總則, 修訂4版, 臺北: 五南。
- 林鈺雄(2003), 論詐欺罪之施用詐術, 臺大法學論叢, 32卷3期, 頁117-147。
- (2018), 新刑法總則, 6版, 臺北: 自版。

- 張麗卿（2018），刑法總則理論與運用，7版，臺北：五南。
- 許恒達（2013），公職詐欺與財產損害——以臺灣高等法院九十九年度矚上易字第二號刑事判決為討論中心，月旦法學雜誌，217期，頁15-32。
- （2013），偽裝化緣與捐贈詐欺——評板橋地院88年度易字第4578號判決，台灣法學雜誌，218期，頁132-142。
- （2016），變質的友情：侵入住居與妨害性自主之個案檢討，月旦法學教室，166期，頁24-26。
- 許澤天（2017），刑法各論（二）：人格法益篇，臺北：自版。
- （2018），刑法各論（一）：財產法益篇，2版，臺北：自版。
- 陳子平（2017），刑法各論（上冊），3版，臺北：元照。
- （2017），刑法總論，4版，臺北：元照。
- 曾淑瑜（2013），騙人不一定成立詐欺罪，台灣法學雜誌，225期，頁160-167。
- 惲純良（2017），詐欺罪中財產損害之判斷——「財產危險」概念的回顧與展望，臺北大學法學論叢，103期，頁119-192。
- 黃榮堅（1990），刑法解題——關於詐欺等財產犯罪，輔仁法學，9期，頁99-110。
- 葉培靚（2018），因詐術取得被害人同意或承諾有效性的檢討，國立中正大學法律學系研究所碩士論文。
- 廖晉賦（2009），「懷疑」是否構成詐欺罪之「陷於錯誤」——以「被害者學理論」為中心，刑事法雜誌，53卷3期，頁99-142。
- 褚劍鴻（2006），刑法分則釋論（下冊），增訂4版，臺北：臺灣商務。
- 蔡聖偉（2008），概說：所有權犯罪與侵害整體財產之犯罪（上），月旦法學教室，69期，頁52-60。
- （2008），概說：所有權犯罪與侵害整體財產之犯罪（下），月旦法學教室，70期，頁48-59。

—— (2016), 論強制性交罪違反意願之方法, 中研院法學期刊, 18期, 頁41-109。

盧映潔 (2018), 刑法分則新論, 修訂13版, 臺北: 新學林。

薛智仁 (2013), 巧取公職之詐欺罪責——評臺北地方法院九十八年度金重易字第九號及臺灣高等法院九十九年度矚上易字第二號刑事判決, 月旦法學雜誌, 212期, 頁200-224。

2. 外文部分

足立友子 (2013), 詐欺罪における「欺罔」と「財産的損害」をめぐる考察——損害概念の多義性と中間結果としての錯誤に着目して——, 收於: 川端博、浅田和茂、山口厚、井田良編, 理論刑法学の探究6, 頁133-164, 東京: 成文堂。

井田良 (2007), 処分行為(交付行為)の意義, 收於: 西田典之、山口厚、佐伯仁志編, 刑法の争点, 頁182-183, 東京: 有斐閣。

—— (2014), 詐欺罪における財産的損害について, 法曹時報, 66卷11号, 頁2989-3016。

井上祐司 (1963), 被害者の同意, 收於: 日本刑法学会編, 刑法講座第2卷, 頁160-179, 東京: 有斐閣。

大塚仁、河上和雄、中山善房、古田佑紀編 (2000), 大コンメンタール, 第13卷(第246条～第264条), 2版, 東京: 青林書院。

葛原力三 (2017), 財産的損害のない詐欺罪, 收於: 井田良、川口浩一、葛原力三、塩見淳、山口厚、山名京子編, 山中敬一先生古稀祝賀論文集(下巻), 頁207-244, 東京: 成文堂。

川原広美 (1980), 刑法における被害者の同意(2・完)——自律性原理の確認——, 北大法学論集, 31巻2号, 頁757-797。

木村光江 (2017), 「欺く行為」における「重要な事項」の判断基準, 收於: 井田良、川口浩一、葛原力三、塩見淳、山口厚、

- 山名京子編，山中敬一先生古稀祝賀論文集（下卷），頁189-206，東京：成文堂。
- 佐伯仁志（1985），被害者の錯誤について，神戸法学年報，1号，頁51-123。
- （2006），詐欺罪の理論的構造，收於：山口厚、井田涼、佐伯仁志編，理論刑法学の最前線II，頁95-133，東京：岩波書店。
- （2011），詐欺罪（1），法学教室，372号，頁106-115。
- （2011），詐欺罪（2），法学教室，373号，頁112-120。
- 佐藤陽子（2007），被害者の承諾（1）：各論的考察による再構成，北大法学論集，58卷3号，頁1067-1101。
- 曾根威彦（1978），「被害者の承諾」と犯罪論体系——被害者の承諾・その二——，早稻田法学，53卷1・2号，頁67-104。
- 高橋則夫（2018），刑法各論，3版，東京：成文堂。
- 団藤重光（1990），刑法綱要各論，3版，東京：創文社。
- 富川雅満（2016），詐欺罪における被害者の確認措置と欺罔行為との関係性（三・完）——真実主張をとまなう欺罔をめぐるドイツの議論を素材として，法学新報，122卷7・8号，頁223-263。
- 西田典之著、橋爪隆補訂（2018），刑法各論，7版，東京：弘文堂。
- 橋爪隆（2011），詐欺罪成立の限界について，收於：植村立郎判事退官記念論文集編集委員會編，植村立郎判事退官記念論文集——現代刑事法の諸問題第1巻第1編：理論編・少年法編，頁175-202，東京：立花書房。
- （2017），詐欺罪における交付行為について，法学教室，436号，頁76-88。
- 林幹人（1984），財産犯の保護法益，東京：東京大学出版会。
- （2007），刑法各論，2版，東京：東京大学出版会。

林美月子(1994), 錯誤に基づく同意, 收於: 松尾浩也、芝原邦爾編, 刑事法学の現代的状況——内藤謙先生古稀祝賀, 頁21-53, 東京: 有斐閣。

藤木英雄(1976), 刑法講義各論, 東京: 弘文堂。

宮野彬(1979), 被害者の同意, 收於: 中山研一、西原春夫、藤木英雄、宮澤浩一編, 現代刑法講座第2卷・違法と責任, 頁109-123, 東京: 成文堂。

三代川邦夫(2017), 被害者の危険の引受けと個人の自律, 東京: 立教大学出版会。

山口厚(1998), 問題探究 刑法総論, 東京: 有斐閣。

——(2006), コメント(佐伯仁志, 詐欺罪の理論的構造), 收於: 山口厚、井田涼、佐伯仁志編, 理論刑法学の最前線Ⅱ, 頁134-141, 東京: 岩波書店。

——(2010), 刑法各論, 2版, 東京: 有斐閣。

——(2014), 詐欺罪に関する近時の動向について, 研修, 794号, 頁3-12。

——(2015), 新判例から見た刑法, 3版, 東京: 有斐閣。

山中敬一(1983), 被害者の同意における意思の欠缺, 関西大学法学論集, 33巻3・4・5号, 頁918-1006。

——(2015), 刑法総論, 3版, 東京: 成文堂。

——(2015), 刑法各論, 3版, 東京: 成文堂。

吉田敏雄(2017), 被害者の同意における意思瑕疵, 收於: 井田良、川口浩一、葛原力三、塩見淳、山口厚、山名京子編, 山中敬一先生古稀祝賀論文集(上巻), 頁237-261。東京: 成文堂。

On Property Damage and Victim's Reliance on the False Representation in Fraudulence

*Shih-Hsuan Huang**

Abstract

This article aims to limit the risky expansion of criminal punishment against fraudulence. This article first examines the judicial practice in Taiwan and points out the problems of over-expanding fraudulence. It then explores possible doctrinal theories for judging property damage and victims' mistakes in fraudulence. The ultimate objective of this article is to reconstruct the formation and definition of fraudulent in Taiwan.

KEYWORDS: reliance on the false representation of the victims, consent of the victims, theory of "mistakes relating to legal interests", fraud, property damage.

* Associate Professor, Department of Law, National Chung Cheng University.